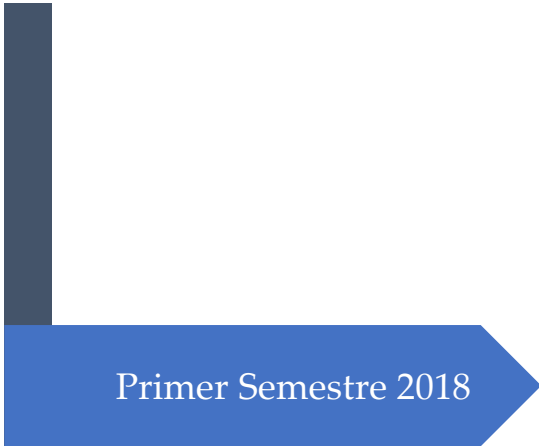
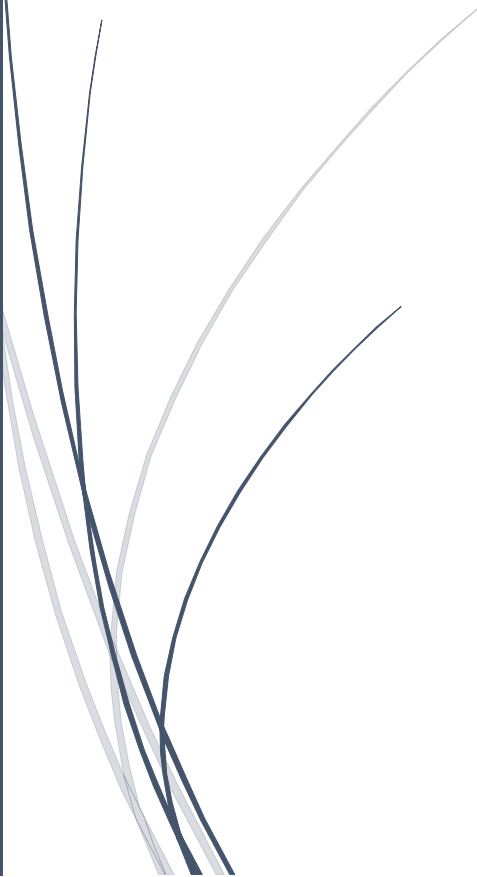


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the text 'Primer Semestre 2018'.

Primer Semestre 2018

El Comerciante y Bases de la Contratación mercantil

Profesor Roberto Ríos

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

Ariel Urzúa de la Barra
VAGRANT

TEMARIO PARTE GENERAL (DEL PROFESOR)

1. **Derecho y actividad económica**
2. **Evolución histórica**
3. **Concepto y características del derecho mercantil**
4. **Fuentes del derecho mercantil**
5. **¿Cuándo un contrato es mercantil?**
 - 5.1. Análisis doctrinal:
 - Dimensión objetiva del derecho comercial
 - Dimensión subjetiva del derecho comercial
 - Acto de comercio
 - Contrato mercantil
 - Acto de consumo (como acto jurídico). Antes era analizado desde la perspectiva meramente civil.
6. **Relevancia en la determinación del contrato mercantil:** Tiene relevancia en cuanto a la formación y ejecución del contrato, en los siguientes aspectos:
 - 6.1. Formación del consentimiento:
 - Reglas generales reguladas en el Código de Comercio, llenando el vacío de la formación del consentimiento en el Código Civil. Es importante fraccionar el concepto de contrato civil y el de consumo. Hay que identificar cuando un contrato es civil o está inserto en una relación de consumo.
 - Reglas especiales
 - Reglas especiales de la Ley de Protección al Consumidor
 - Reglas especiales en el EC
 - Reglas especiales en materia de vicios del Consentimiento
 - Tópico deberes de información: se analizará la información desde el punto de vista del cumplimiento del contrato.
 - 6.2. Ejecución del contrato: (reglas especiales)
 - Dación en arras
 - Plazos
 - Pago
 - Prueba de la obligación
 - Prescripción: existen dos plazos lineales. Cuando se deriva responsabilidad por incumplimiento del contrato, la regla general siempre es de 5 años. Cuando hay una responsabilidad que causa daño por ser extracontractual, la regla general es de 4 años. En el Código de Comercio existen reglas especiales de prescripción y de corto plazo.
7. **Condiciones generales de la tramitación:** estudiaremos esto, porque una parte importante de la tramitación se realiza en base a estas condiciones generales (por ejemplo, las transacciones de internet)
 - Contratos en masa
 - Condiciones generales del contrato
 - Condiciones generales de la contratación
 - Condiciones generales, acto de consumo y adhesión
8. **Protección al consumidor:**
 - 8.1. Estatuto normativo del consumidor

8.2. Acto de consumo y acto mixto (art. 3 del Código de Comercio y art 2 de la LPC)

8.3. Ley de protección de los derechos de los consumidores

- Función tutelar
- Concepto de consumidor:
 - Art. 1 n° 1 LPC
 - Ley estatuto pyme art. 9
 - Directivas europeas
- Concepto de proveedor
- Derechos y deberes del consumidor
- Normas especiales sobre formación del consentimiento
- Responsabilidad por incumplimiento
- Acciones y solución de controversias
- Sernac: el Tribunal Constitucional acaba de dictar un fallo (bastante criticado) donde, en un control preventivo de constitucionalidad, despedazó la ley que tenía por objeto modificar la ley de protección al consumidor y entregarle facultades especiales al Sernac. El Sernac hoy en día es un órgano persecutor (tal como el Ministerio Público) y esta modificación, pretendía otorgarle todo tipo de facultades al Sernac, como sancionatorias o facultades de potestad normativa para interpretar la ley. Esto fue cercenado por el Tribunal Constitucional.

6 de marzo de 2018

I. INTRODUCCIÓN

Oficina Ríos en 5to piso. Secretaria Sandra Concha.

- **Caso práctico /trabajo en grupos:** deberá identificarse el hecho jurídico y posteriormente, se deberá presentar una solución a ese problema (el profesor se fija en la creatividad). Para esto, deberá realizarse un trabajo de investigación. Se fijará una fecha en la que cada equipo deberá hacer una presentación oral (máx. 10 minutos) sobre el caso que se recibió, con la estructura de problema – solución. Para este tipo de presentaciones, se recomienda a no usar PPT. Además de la exposición oral, deberá presentarse un informe ejecutivo de máximo 3 páginas.
- **Solemne escrita**
- **Examen oral:** 50% de la nota final. Se fijará una fecha para rendir recuperativas, **solo para aquellos que se justificaron.**
- **Asistencia:** 75%
- **Ayudantes:** Pablo Atiz, Valentina Ponce

Bibliografía (más importante):

- ✓ Oswaldo Contreras: Instituciones del Derecho Comercial (última edición de 2016)
- ✓ Ricardo Sandoval: El primer tomo de Teoría General de Derecho Comercial (mejor en materia de Transporte)
- ✓ Eduardo Jequier: El primer tomo de Derecho Comercial
- ✓ María Fernanda Vásquez: Comerciantes y Sociedades
- ✓ Proceta: (Manual un poco desajustado)
- ✓ Arturo Alessandri
- ✓ Materia sobre comercio electrónico: se subirá a la página
- ✓ Materia sobre protección al consumidor: se subirá a la página

Código de Comercio:

Tarea: Leer mensaje del Código de Comercio.

Materias:

- **Ríos:** Concepto positivo de derecho mercantil y Fuentes. Aspectos Generales de la contratación comercial. Aspectos básicos de la protección al consumidor. Contrato de transporte
- **Vial:** Acto de comercio, comerciante, establecimientos y empresas. Compraventa mercantil y suministro.

7 de marzo de 2018

¿Por qué tenemos una regulación en el Código de Comercio tan antigua y que aún subsiste en la actualidad? ¿Cómo se caracteriza? Esta regulación es completamente decimonónica (siglo XIX). Las modificaciones han sido pocas. ¿Qué relación existe entre esta norma y el tráfico y la actualidad?

1. DERECHO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.1. El problema económico:

El problema se resume en la existencia de Infinitas necesidades y escasos recursos. El derecho si tiene algo que decir respecto de este problema. Frente a este problema, lo que ha hecho la sociedad y el estado moderno, es implementar sistemas para regular esta problemática, por lo tanto, se entiende que **el problema económico se desarrolla sobre la base de las reglas jurídicas**. Es el derecho el que establece el contexto del desarrollo del problema económico. El derecho como ciencia tiene más de 2000 años, la economía no. La economía nace de acuerdo a la bibliografía económica, con la famosa obra "*La Riqueza de las Naciones*" de Adam Smith. Hay que tener claro que es el derecho el que establece las reglas para regular el problema económico. En esto último, ¿qué tiene que decir el derecho comercial? R: si se hace un análisis histórico y se verifican hitos en la historia, podemos darnos cuenta si existen reglas del derecho mercantil:

Roma: En Roma la doctrina ha señalado que no se puede identificar el derecho mercantil como tal. Los romanos desarrollaban el comercio o su tráfico sobre la base del *ius civile* y con la expansión del imperio fueron creando estatutos diferentes como el *ius gentium* que permitían las relaciones entre aquellos que no eran ciudadanos romanos y los que sí lo eran. No quiere decir que los romanos no conocieran el comercio, sino que el derecho mercantil como lo define la doctrina, no se encuentra en Roma, principalmente por el **exceso de formalismo**. Una de las particularidades del derecho mercantil, es evitar el exceso de formalismo. El derecho mercantil se aparta del derecho romano porque era excesivamente formal y se quería evitar el cumplimiento de esas formas. La razón principal detrás de esto, es porque el formalismo entorpece el comercio, impide la agilidad del tráfico.

Conclusión: Existe una estrecha relación entre la economía y el derecho y especialmente el tráfico. Esto porque el tráfico regulado por el derecho mercantil, tiene por objeto abordar el problema económico (mucha necesidad, pocos recursos)

2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO MERCANTIL

2.1. Evolución por periodos históricos

Existen dos grandes autores que nos ayudarán a entender la relación que existe entre la economía, el fenómeno del capitalismo y el derecho mercantil. Este señor se llama Werner Sombart que escribió dos grandes obras, una de ellas es "El Burgués" que revisa la problemática del espíritu humano respecto del capitalismo y la otra se llama "Capitalismo moderno". El otro autor se llama Francisco Galgano que es un jurista que se hizo cargo de la evolución completa del derecho mercantil. Estos autores serán la base de lo que se comentará en esta clase.

Lo importante de sus planteamientos es el **cuándo podemos identificar en el proceso de desarrollo histórico, un cambio en el sistema económico y en base a ese cambio, el surgimiento del derecho**

mercantil. En base a esto, se enunciarán distintas etapas o periodos históricos y posteriormente se evaluarán las etapas jurídicas de esta evolución. En relación a esto, Sombart señala fundamentalmente que:

- a) **El Medioevo:** el ser humano actúa por instinto de subsistencia, no tenía internalizado una actividad productiva con el objeto de obtener una rentabilidad, sino que quería alimentarse y vestirse.
- b) **En la Época Pre-industrial:** Lo anterior cambia y el comercio se expande. El ser humano ya no se ocupa solamente de su propia subsistencia, sino que busca mecanismos a través de actividades individuales o asociadas para obtener mayores beneficios o lucro en la actividad que desarrolla¹
- c) **Época Post-industrial:** Está representada principalmente por el desarrollo de la tesis de Adam Smith y que se identifica como la masividad de la actividad productiva.
- d) **Empresa y economía neo industrial:** Hay una ruptura en el tráfico mercantil porque hay un desarrollo exponencial de la producción y de la producción en masa de bienes y servicios, lo que genera un impacto en la regulación.
- e) **Empresa y globalización (masividad y desmaterialización del contrato):** Y hoy en día, generalmente la actividad mercantil la desarrolla un empresario, nos vemos enfrentados a otro fenómeno que algunos autores lo han calificado como la masividad y desmaterialización del contrato. (El papel desaparece)

La pregunta que nos haremos posteriormente es ¿cómo si una regla ubicada en la época preindustrial, puede resolver un problema ubicado en la etapa de la empresa y globalización? **¿Cómo una regla tan antigua resuelve algo tan moderno?**

*Hoy en día existe un problema que no ha sido resuelto ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Es importante determinar la categoría del acto, para saber que norma se aplica para la resolución de un problema jurídico (¿Ley de protección al consumidor? ¿Código de Comercio? ¿Código Civil?)

2.2. Evolución histórica (en periodos jurídicos):

Derecho romano y derecho mercantil: el derecho romano no reconoce el derecho comercial como una rama autónoma del derecho, ya que este se caracteriza por haberse liberado de todos los formalismos propios del derecho romano, ya que el derecho mercantil así no existe.

En el periodo de formación del derecho comercial o mercantil, se pueden diferenciar las siguientes etapas:

(*) **Pregunta en clases:** Comprar en un retail, no es un acto comercial, sino que se conformó una relación de consumo. Y si por casualidad ocurriera un problema con el producto comprado, este

¹ El derecho mercantil tiene como esencia el lucro, el empresario que desarrolla una actividad –y así lo entiende el derecho– tiene por finalidad el desarrollo de un lucro o de una actividad que genere beneficios para que ejecute la actividad ya sea individualmente a través de un mecanismo de individualización o sea colectivamente.

problema debe ser resuelto en el contexto de las normas de protección al consumidor. Este no es un acto de comercio. Incluso, nuestro derecho tiene una particularidad muy rara, porque la ley pyme reenvía esta relación a la ley de protección al consumidor. En general, existen estos tres tipos de relaciones:

- Btb: empresario con empresario
- Ctc: consumidor con consumidor
- Btc: empresario con consumidor (que se rigen por el ordenamiento civil)

(Me falta la explicación del profesor sobre la razón del reenvío de la ley pyme a la del consumidor, el profesor se adelantó a la materia, por lo que es mejor explicarlo posteriormente y no confundir)

a) **Etapas formativas del ius mercatorum**

Está representada esencialmente en la actividad de los comerciantes en la península itálica de los siglos XI y XII. Se inicia un periodo de expansión del comercio, de una actividad lucrativa actividad económica en este sector. Si bien este es un análisis jurídico de Galgano, Sombart señala que es en esta época en que surge el capitalismo, porque la actividad que desarrolla el comerciante responde a reglas de **organización y contabilidad**. Sostiene que una de las razones del nacimiento del capitalismo **son las decretales² papales de Gregorio XII que prohíben la usura**, es decir el rendimiento del dinero, sobre el derecho. Al prohibirse de usura, el capital y el dinero va a aumentar en base a actividad productiva y no es a base a la actividad del resto. Son los mismos comerciantes los que crearán el derecho mercantil o comercial. Es un derecho basado en la costumbre.

b) **Etapas de consolidación del derecho mercantil**

Lo que ocurre, es que, en el transcurso del tiempo, estos comerciantes **se agruparán en corporaciones o asociaciones o gremios –en el medioevo–**. Hay una cantidad importante de estas corporaciones de comerciantes en el norte de Italia que se agrupan con el fin de reordenar la problemática de la aplicación de las reglas de derecho que tienen su fuente en la costumbre. **Crean un estatuto propio que recoge estas costumbres y además incorporan un sistema de resolución de controversia sin forma de juicio.**

(*) **Shylock y Antonio (en el Mercader de Venecia):** Sin forma de juicio, se asocia a esta historia. Ya que aquí se retrata la forma de resolver las controversias sin un juicio como tal.

En este proceso de consolidación, los comerciantes debían incorporarse a un registro de la agrupación o asociación para poder regirse de aquellas reglas contenidas en el estatuto y en este sistema de Solución de controversias y además de la posibilidad de participar en la actividad mercantil de todos aquellos que estaban agrupados en esta asociación. Lo que sucedió es que aquellos incorporados en el registro/estatuto, comenzaron a comerciar con aquellos que NO estaban en el registro/estatuto. Aquí surge la problemática de qué hacer cuando un comerciante registrado y uno no registrado ¿Qué regla se aplica cuando se comercia con los que no son parte de las asociaciones? **Por lo tanto, se integran estas normas de los registrados a aquellos que no formaban parte de las agrupaciones.** Es exactamente lo mismo que ocurre hoy con el Código de Comercio, ya que sus normas se aplican a los

² Duda sobre esta palabra

comerciantes, pero, ¿Qué ocurre cuando la otra parte no es comerciante? Esto es algo que los franceses intentaron resolver, pero a pesar de que creyeron resolverlo, no pudieron.

c) **Proceso de codificación (tesis objetivas y subjetivas)**

Exista una ruptura al sistema existente. Luego de la etapa anterior, los franceses intentaron solucionar el problema. El proceso de codificación del siglo XIX lo lidera Francia sobre la base de los principios libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, lo que ocurre es que los franceses argumentaron que el derecho mercantil como se entendía en ese momento (disperso en diversos estatutos y aplicado de forma privilegiada a los registrados) **debía ser derogado rápidamente** y dictaron su código propio de comercio. Y al igual que Gabriel Ocampo, crearon un estatuto con una enumeración de actos que ellos denomina como **“actos de comercio”** y que están así en nuestro Código (artículo 3º “Son actos de comercio...”). Serán finalmente los actos que se regirán por las normas del derecho mercantil que está única y exclusivamente contenido en el Código. Esta era la visión de Napoleón.

(*) **La tumba de Napoleón tiene dos particularidades:** hay que inclinarse y cuando se baja hay una mano con el Digesto y otra mano con el código de comercio. Lo que simboliza es el traspaso del derecho antiguo al moderno, en lo relacionado a la forma de ver el comercio.

Nuestro sistema no estuvo ajeno a este proceso de codificación. En 1865 se dictó un Código de Comercio con vacancia legal de 2 años y que entró en vigencia en el año 1867. Se optó a crear un Código de Comercio, por una obsesión de Portales, ya que el mismo mensaje del código lo señala en su primer párrafo:

“La codificación de nuestras leyes en general ha sido mucho antes de ahora una necesidad sentida por todos, reconocida por los hombres de ciencia, y debidamente estimada por los Gobiernos que sucesivamente han regido los destinos de la República; mas esta necesidad se ha manifestado con el carácter de imperiosa y apremiante respecto de la legislación mercantil, que nos pone en inmediato contacto con las diversas naciones del globo que buscan en nuestro suelo los beneficios del cambio de los respectivos productos”.

¿Por qué se codifica? ¿Por qué tenemos códigos? Se utilizó la herramienta de la codificación –desde el punto de la ciencia del derecho- porque se quiere una ordenación sistemática (sistematizar tiene como objetivo crear un cuerpo armónico que facilite la interpretación de la ley o de las reglas) y lógica de todo el ordenamiento comercial. No se sistematiza por un mero objetivo de ordenación, sino que el trabajo intelectual del intérprete se facilita, ya que es uniforme y armónico. Esto es lo que busca el proceso de codificación en Francia, luego de los españoles en 1829, le siguen los italianos y por último los alemanes. Luego de que los franceses dictan su código se inicia un proceso de interpretación y desarrollo doctrinal, que va a llevar a dos tesis explicativas del derecho mercantil:

- **La tesis objetiva del derecho mercantil:** apunta a que es el acto el que determina la mercantilidad (el que se encuentra en el Código de comercio). Es el acto lo que de alguna manera va determinando la particularidad de comerciante del individuo. Esta es la teoría recogida por nuestro sistema, (los redactores no pensaron en teoría objetiva o subjetiva) pero solo pensando en iluminar el sistema previo que existía previo al sistema de codificación, en el que existían estatutos que se aplicaban con preminencia a los comerciantes.
- **La tesis subjetiva del derecho mercantil:** Es la particularidad del comerciante, del individuo, la que va a determinar la calidad del acto. Los alemanes siguieron la teoría subjetiva en su proceso de codificación mercantil

Hoy en día hay un desajuste en el sistema, porque en el artículo 3 en su enumeración no taxativa, si se revisa, hay actos de comercio que subsisten como tal, pero que en la nota al pie del código son modificados, lo que obedece a ciertas fuentes –por ejemplo, todo lo relacionado a valores, fue modificado en 1930-, incluso fuentes subjetivas. Además, se han ido incorporando varios actos enumerados en el artículo 3, que podrían calificarse como actos de consumo.

Las problemáticas entre los sistemas del Common law y el Civil law son bastante complejas en temas comerciales. Se tiene una forma de pensar y crear el derecho de una forma totalmente distinta y no se reconoce normas tan importantes como las de la convención de Viena sobre compraventa de mercaderías (muy asentada en el Civil law). Además, para ellos la jurisprudencia es importantísima, para nosotros no. El Brexit tuvo grandes efectos que descontinuaron todos los intentos de unificación de Europa, ya que Inglaterra dejará de lado muchas reglas bastante importantes.

Una vez que culminó el proceso de codificación mercantil, podríamos señalar como último hito el proceso de codificación alemán de 1900.

15 de marzo de 2018

Correo ayudante: acponce@uc.cl

Trabajo en equipo 1 de junio

¿Para qué sirve diferenciar los actos civiles y los mercantiles? R: Por las normas aplicables y sus efectos particulares. Aun así, los efectos en general pueden ser muy similares (actos de comercio y civiles), pero si existen reglas especiales que se aplican –por ejemplo- a la compraventa mercantil y no a la civil. Todo aquello que no esté regulado en el código de comercio, se encuentra en el código civil (código base), por eso es importante la mercantilidad del acto.

En la clase anterior quedamos en el proceso del desarrollo histórico del derecho mercantil.

d) Fenómeno de la descodificación

Paralelo a esto, el comercio está siendo objeto de un cambio radical. La actividad mercantil y el tráfico cambian, los modos de intercambio se modernizan. Se incorporan fenómenos que no existían a principios del siglo XIX. A fines del siglo XIX los procesos industriales se automatizan (las producciones en masa) y ya en esa época las actividades bancarias u otras, la contratación de ese tráfico se realiza a través de contratos estandarizados o formularios. Entonces la visión de Andrés Bello y Ocampo del comercio, es absolutamente distinta a aquella que se está desarrollando a fines del siglo XIX e inicios del XX. Esto es lo que provoca el fenómeno de la descodificación, el que se puede analizar desde una doble dimensión:

- **La derogación de normas contenidas en el Código respecto de normas específicas**
- **La elaboración y dictación de normas para abordar materias que no estaban contempladas en los códigos.**

Esto provoca un tremendo problema, ya que nuestro Código Civil en su artículo 4 establece lo siguiente:

Art. 4º. Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código.

Entonces se vuelve a lo que existía antes, que podría calificarse como pre-codificación o dispersión normativa. El Código de Comercio tiene 500 páginas y el Código llega a lo más, a la página 130, el resto es apéndice o normas descodificadas. Existe una cantidad de normas que están dispersas porque los civilistas dicen que es civil y los mercantilistas dicen que es mercantil. Código significa Codex o libro. El gran problema al que nos veremos enfrentados, será la determinación de la norma aplicable. Evidentemente hoy estamos enfrentados a este problema sobre cual ley prima sobre otra, donde hay más especialidad respecto de otra, etc.

¿Cómo se resuelve la problemática de la dispersión normativa?

Existe una crítica doctrinal respecto del acto de comercio. Ya analizamos con el profesor Vial, que frente a esta teoría objetiva del acto de comercio, en principio rígida (y descontextualizada del tráfico actual), surgieron algunas tesis que buscan provocar una válvula de escape y poder adaptar el texto normativo frente al tráfico mercantil, estas son la **teoría del acto mixto** (inserta en el artículo 3 inciso primero del código) y la teoría de lo accesorio, que busca expandir la aplicación del artículo tercero.

Todo esto provocó desde el punto de vista DOCTRINAL, la crítica de la teoría objetiva del acto de comercio, y causó la elaboración de dos teorías, para explicar el derecho mercantil y acto de comercio:

- **Teoría de los actos en masa (revisar):** elaborada por un autor alemán llamado Heck. Es una teoría que busca justificar las problemáticas de la teoría de la accesoriedad o la teoría del acto mixto. Es una tesis que es absorbida por la teoría de la empresa. El acto ya no está relacionado con los actos individuales, sino que la base del mercado son los actos en masa. Es un sistema estandarizado de producción de bienes y prestación de servicios.
- **Teoría de la empresa:** toda aquella norma que tenga por objeto regular los actos de la empresa, debe ser categorizado como derecho mercantil. Aquí se encuentran el ordenamiento jurídico alemán e italiano que han estructurado la conceptualización del derecho comercial y por tanto el ámbito de aplicación de la norma, en la teoría de la empresa.

En el ordenamiento comercial español, por ejemplo, sus tratados de comercio han superado el análisis del acto de comercio, ellos solo contratan. En Chile estamos en un periodo de desarrollo y cambio constante, donde encontraremos que la jurisprudencia está más decantada por la teoría objetiva y no tanto por la teoría de la empresa.

Wieland (autor de esta teoría) *señala que el cambio en la economía en la perspectiva de las fuentes de producción ha provocado que el derecho mercantil pase de un derecho del comercio, a un derecho de la empresa, entendida esta como una forma de organización que permite comprender el derecho mercantil y la evolución del derecho mercantil, de la mano del capitalismo.*

Esta teoría de la empresa es perfeccionada por **Schmidt**. La crítica que la doctrina formuló a Wieland fue que la empresa, en su concepto unívoco, comprende no solamente los elementos de producción, sino que hay otros que integran la empresa que no son propios del derecho mercantil, por ejemplo, el derecho laboral. Schmidt perfeccionó esta teoría, diciendo que la empresa es una unidad económica organizada a través de la cual el empresario actúa en el mercado y que posee ciertas características esenciales:

- **Un mínimo de medio personales y materiales**
- **Una mínima medida de dirección unitaria**
- **Una unidad económica en el mercado:** el empresario debe desarrollar un giro claro.

Esta teoría se ha desarrollado en muchos países, cuya regulación/codificación mercantil es muy parecida a la nuestra. En nuestro ordenamiento, la teoría de la empresa, si bien tiene una teoría doctrinal, la doctrina ha intentado encontrar ciertas normas del Código de comercio que reconozcan a la empresa como el protagonista principal.

¿El concepto de empresario, limita o extiende el concepto? (revisar) R: el concepto de empresa como una unidad económica que se desenvuelve en el mercado, ¿es más flexible o más rígido que la estructura del artículo 3 del Código del comercio? Para responder esto, debemos darnos cuenta si es que se adecúa al tráfico mercantil o no lo hace. Finalmente, esta teoría surge porque la auto emancipación y la masividad de la producción, provoca que fueran naciendo una serie de actos que están insertos en el mercado y que finalmente debieran ser regulados por el derecho mercantil.

3. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

3.1. Concepto de derecho mercantil

La doctrina ha hecho varios ejercicios para definirlo. En nuestra doctrina la profesora María Fernanda Vázquez lo ha definido como *“el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones que emergen del comercio y que vinculan a los comerciantes entre si y a estos con los no comerciantes”*

3.2. Características del derecho mercantil

- a) **Es privado:** aunque con ciertas particularidades agregadas por la doctrina moderna. La actividad que desarrollan los comerciantes, podría no solamente estar vinculado al derecho privado. Por ejemplo: hoy en día, todas las actividades que ejecutan ciertas sociedades anónimas abiertas, administradoras de fondos de pensiones, bolsas de comercio, intermediadores de seguros, son **actividades reguladas**. Entonces hay una interacción entre normas de derecho público y normas de derecho privado.

Todos aquellos sujetos que están bajo el control de un órgano supervisor, pueden ser objeto de la aplicación de sanciones, que pueden ir desde censuras a multas, que están bajo la base de los procesos administrativos –por ejemplo, los procesos de reclamación (derecho público). **Este es un proceso que se instala con fuerza a partir de la crisis de 1930, en la que se crean una serie de órganos que tiene por objeto regular las actividades de ciertas empresas** que desarrollan un giro que está comprometido con el interés y la fé pública y el patrimonio de aquellos que podrían ser considerados como clientes en el derecho mercantil de bancos, fuentes de inversión, aseguradoras, etc.

¿Podría considerarse privado? R: En su base sí, pero conversa cada día más con normas de derecho público.

- b) **Es especial:** Es especial en aquellos casos u ordenamientos jurídicos que no han recogido la teoría unitaria del derecho privado, como Italia (Código Civil –tanto para contratación civil como mercantil- 1942) o Argentina, que tiene un Código único.
- c) **Es dinámico:** el comercio es dinámico y cada día más.
- d) **Derecho que tiende a la uniformidad:** hay diversos intentos que llevan a los estados a tener criterios uniformes en la regulación del comercio (salvo Inglaterra con el Brexit)
- e) **Descodificación en parte:** hay una gran cantidad de normas fuera del Código de Comercio.
- f) **Transfronterizo:** por la dinámica y la forma en que se desarrolla, tiende a aplicarse no solo en un territorio delimitado, sino que hay reglas o estatutos normativos que tienen reglas especiales en materias de problemática transfronteriza. Esto ocurre mucho en Europa, donde se lleva hace años un intento hacia la uniformidad y transfronterizidad.
- g) **Derecho histórico:** tiene origen histórico esencialmente.

3.3. Fuentes del derecho comercial

1. **La Constitución Política de la República:** el 19 N° 21 principalmente.
2. **El Código de Comercio:** por ejemplo, su artículo 3
3. **El Código Civil:** porque suple aquellas materias no reguladas en el Código del comercio
4. **La Costumbre:** si constituye fuente, a diferencia del civil. La costumbre ¿se aplica por ejemplo a la actividad que realiza una empresa de retail? R: no, porque no es una relación mercantil (en la cual si se permite esta fuente), sino una de consumo regulada por la ley de protección al consumidor.
5. **Los tratados internacionales:** hay uno que destaca: la convención de vienes sobre la compraventa internacional mercaderías (1980), tiene ciertas estructuras que realmente se ajusta al tráfico, sobre todo en la parte de incumplimiento. Se aparta del concepto de compraventa concebida en el siglo XIX (la compra de almacén o de animales). Esta compraventa está relacionada con la actividad desarrollada por la empresa.
6. **Leyes especiales:** (el profesor pedirá ejemplos en la prueba)
 - Ley de protección de los Derechos de los Consumidores (reglamentos)
 - Ley de arbitraje comercial internacional
 - Ley 20.416 y su estatuto PYME
 - La ley 18.092 sobre letras de cambio y pagarés
 - Ley 18.552 sobre títulos de crédito
 - Ley 18.045 sobre mercado de valores
 - Ley 18.046 sobre sociedades anónimas
 - Ley 3.918 sobre sociedades de responsabilidad limitada
 - DFL 251 sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio
 - **Ley 21.000 Sobre comisión para el mercado financiero:**

-
- i. **Esta ley cambia la estructura unipersonal –superintendencia de valores y seguros- por una estructura colegiada** para la supervisión de los sectores de seguros y valores -y luego la banca-. Se decide entre un grupo de individuos que forman parte del consejo de la comisión.
 - ii. **Se crea una unidad especializada de investigación por infracciones a la normativa que se encuentra dentro del marco de atribuciones de esta comisión.** Es una unidad especializada que cumple funciones de persecución y de sugerencia de aplicación de sanciones al Consejo.
 - iii. **En Chile pasó algo bastante curioso, ya que los sistemas de control y supervisión siempre han sido oscilantes y el primer hito que se produce en el área de la supervisión es la crisis subprime.**

En Inglaterra se tiene un sistema de supervisión integrado, es decir, un solo órgano supervisa todos los sectores de **banca, seguros y valores** y todos los intereses que son necesarios de supervisar: **protección al consumidor, solvencia y conducta de mercado de las entidades reguladas**. Entonces, este sistema integrado que se veía perfecto, tuvo un quiebre con la crisis subprime producido por problema de un énfasis en la supervisión.

La tendencia del órgano de supervisión integrada, era dar énfasis en el objetivo de protección a los consumidores y un descuido a los objetivos de solvencia y conductas de mercado. Esto provocó que los riesgos sistémicos no fueron detectados por la supervisión. Entonces tanto en Europa como en Inglaterra con la comisión Turner, dijeron que debía crearse un sistema llamado “**twin peaks**” con tres órganos diferentes: uno para protección del consumidor, otro para solvencia y otro para conductas de mercado (o solo dos, con estas dos últimas características reunidas) Se propuso en Chile aplicar este sistema, además con el sistema de AFP. ¿Funcionará el sistema? R: nosotros tendremos un sistema de supervisión integrado (todos los sectores en manos de un solo órgano: comisión de mercado financiero) y el intento de darle al Sernac el sector de protección al consumidor, falló rotundamente en el Tribunal Constitucional

- **Ley 20. 190 sobre prenda sin desplazamiento**

20 de marzo de 2018

3.4. **Problemática de la teoría objetiva del derecho mercantil, vs la subjetiva.**

¿Qué dice el mensaje del Código Mercantil?

R: El Mensaje dice en su página 17 párrafo segundo:

Bajo el epígrafe Disposiciones generales se han establecido ciertas reglas que dominan todas las materias del Código y que no era posible consignar en ninguno de los títulos que lo componen, sin alterar el sistema y método de su redacción. Algunas de estas reglas determinan los límites del imperio del Código, y autorizan la aplicación de la ley común y de la costumbre en los casos en que la primera se encuentre deficiente. Los numerosos requisitos que la costumbre debe tener para asumir el carácter de ley supletoria, y la naturaleza de la prueba con que debe ser acreditada en juicio, remueven los inconvenientes de la incertidumbre y vacilación de la ley no escrita, y nos permiten mirar sin recelo la libertad en que queda el comercio para introducir nuevos usos dentro del círculo de lo honesto y lo lícito.

Entre las disposiciones generales se encuentra también la que trata de los actos de comercio que, a más de constituir la materia especial del Código, ofrecen la base más amplia y segura de la jurisdicción mercantil; y mediante la colocación que se les ha dado, se ha evitado la justa crítica dirigida a los códigos que se han reservado la importante noción de estos actos para la ley que reglamenta la competencia de los juzgados de comercio.

El Código de Comercio chileno, es sistematizado por Ocampo de una manera distinta al francés. Los franceses se ocupan del Código de Comercio a propósito de una problemática de jurisdicción competencia de los tribunales de comercio. Nuestro legislador se ocupa de establecer una especie de catálogo enumerado de actos que deben ser considerados como actos de comercio. A pesar de que previo a la entrada de vigencia de este Código, ya existían juzgados especiales de comercio en Valparaíso, los cuales tenían una enumeración (dentro de su reglamento) de cuáles eran los actos de comercio que se entendían en ese momento. Esto es paradójico, porque si los franceses con sus principios querían cambiar los estatutos de los gremios, aun así, establecieron un régimen jurisdiccional especial para la resolución de conflictos de actos concretos, normalmente ejecutados por comerciantes.

Sobre esta base, **¿Qué normas son las que están contenidas en nuestro código y que nos permite resolver la problemática mercantil? (Y por tanto determinar la aplicación de la ley mercantil)**

- a) **Artículo 1:** al disponer que el Código de comercio **(i)** rige las obligaciones de los comerciantes **(ii)** que se refieran a operaciones mercantiles. **(iii)** Las que contraigan con personas no comerciantes, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. **(iv)** Las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Esta es la primera regla que tenemos que tener en cuenta para determinar el ámbito de aplicación del código mercantil.

Existen casos excepcionales en los que siempre, siempre, siempre, siempre, se aplicará la ley mercantil, cualquiera sea la naturaleza del acto:

- **Las sociedades anónimas:** siempre se regirán por la ley de sociedades anónimas (mercantil) aunque su objeto sea civil
- b) **Luego el artículo 1 se vincula con el artículo 7 del Código de Comercio.** Que define quienes son comerciantes: “Son comerciantes los que, teniendo capacidad de contratar, hacen del comercio su profesión habitual”.
- c) **Y en el artículo 8,** se define “No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto (se refiere a las obligaciones)

- d) **Luego de la relación de los artículos 1, 7 y 8, surge el artículo segundo.** Se establece que “En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil”.

En el texto de Garrigues se realiza la interrogante:

- ✓ ¿Qué es y que debe ser el derecho mercantil? R: El autor plantea que “la coexistencia en nuestra legislación de un Código de Comercio y un Código Civil, plantea al intérprete una cuestión de límites entre ambos derechos. En presencia de un acto jurídico cualquiera surge siempre un problema de aplicación de fuentes jurídico privadas.
- ✓ Luego se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál de los dos ordenamientos jurídicos distintos o al menos separados, debe ser aplicado con preferencia? R: Para resolver este problema, sirven las normas delimitadoras del Código de Comercio como los Códigos especiales frente a los Códigos civiles, suelen disponer.
- ✓ En último término, todo problema jurídico se resuelve en la aplicación
- ✓ **El autor hace una crítica al criterio positivista de nuestro ordenamiento en el derecho mercantil.** Y un criterio más laxo o flexible que no solamente está contextualizado en una dimensión positiva del derecho mercantil, sino que en un ámbito más sustancial. Aquí la doctrina mercantilista plantea que debe haber una **armonía entre el método histórico legislativo (de importe positivista) y el método de observación de la realidad económica.** A través de este método de observación económico, se crea la teoría de los actos en masa y de la empresa.

Texto recomendado: “La lucha por el derecho” de Ihering. Generó una revolución al derecho, renunció a su pensamiento y centró el derecho en un concepto de interés. **Planteo que el derecho, no obstante, su concepción abstracta, no puede olvidarse de la realidad** y centra como objeto o motor de las relaciones jurídicas, el interés. A partir de esto, el derecho inicia un proceso de cambio sustancial, muchos de los contenidos de este curso, vienen de la concepción de interés de Ihering.

3.5. **La costumbre como fuente del derecho mercantil.**

Las fuentes del derecho están vinculadas y relacionadas con lo que se ha mencionado. Y dentro de esta enumeración de fuentes del derecho mercantil, la costumbre tiene una particularidad especial. La costumbre tiene una importancia fundamental en el derecho mercantil (porque se formó a raíz de ella o por la norma que le da valor a la costumbre en este tipo de derecho).

La costumbre no obstante los requisitos que se van a mencionar, está vinculada con el dinamismo del derecho mercantil. Esto quiere decir que en el derecho comercial y en el desarrollo del mercado, van surgiendo constantemente reglas de derecho que se integran en este contexto o marco normativo llamado derecho mercantil. Por esta razón la costumbre es importante. Además, tiene más relevancia en el tráfico mercantil internacional, ya que esta se basa como regla primera en la costumbre.

Ahora ¿Cómo reconoce nuestro ordenamiento jurídico la costumbre? R: la regla general respecto de la costumbre, es que tendrá valor solo cuando la ley se remita a ella (a los redactores del Código Civil no les gustaba la costumbre), **¿por qué crear un cuerpo normativo y quitarle valor a la costumbre?** R: porque el proceso codificador francés tenía por finalidad crear un cuerpo sistematizado con certeza de la norma aplicable y evitar lo que ocurría previo al periodo de codificación (ya que utilizando la costumbre existían muchas normativas que se podían aplicar a un mismo caso concreto). En Europa existían muchas normas consuetudinarias y había poca certeza, por esa razón el legislador optó por dejar en segundo plano la costumbre. En los borradores del Código Civil, Bello no quería dejar la costumbre en segundo plano por el tráfico mercantil. **Ocampo, en el Código de Comercio sí reconoce la costumbre, por lo tanto, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es una costumbre que se aplica: fuera de la ley**

¿Qué es la costumbre? *Es una conducta uniforme, reiterada por un determinado grupo, comunidad o localidad durante un periodo de tiempo prolongado y que, en su dimensión jurídica, crea la convicción de constituir fuente formal del derecho objetivo.*

Hay una norma que está en el Código Civil chileno, de donde la doctrina ha derivado el principio pacta sunt servanda: Artículo 1545 del Código Civil. Este artículo es muy importante, ya que un abogado que no sabe de este artículo, no sabe nada. **Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes.** Aquí existe un vínculo que une a las partes contratantes y que no puede terminarse sino por el mutuo acuerdo, o las causas de ineficacia contenidas en la ley. No es una fuente del derecho objetivo como tal. Esto es base para comprender todo el derecho mercantil. Esto no quiere decir que un contrato o condición general, pueda ser considerada como fuente del derecho objetivo.

3.5.1. Elementos y requisitos

Sobre esta definición, la doctrina ha señalado que la costumbre se integra por un elemento material u objetivo y un elemento subjetivo. ¿Qué importancia tiene el determinar si un hecho o conducta puede ser entendida como una costumbre? R: para ver si se aplica o no se aplica y tenerlo en cuenta para fallar (ya que es una regla de derecho). Estos 2 elementos que se analizarán:

- **El elemento objetivo o material:** la conducta que ejecuta la comunidad por un periodo determinado.
- **Elementos subjetivo o espiritual / Opinio iuris:** la convicción de haber generado esa conducta, una regla de derecho.

Art. 4°. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio.

De este artículo se desprenden los requisitos que tiene que tener la costumbre para ser utilizada como fuentes de derechos y para que pueda resolver conflictos mercantiles.

- ❖ Debe tratarse de conductas uniformes
- ❖ Los hechos deben ser públicos o conocidos
- ❖ Debe de tratarse de hechos ejecutados dentro de la República o en una determinada localidad
- ❖ Deben haberse ejecutado en un largo espacio de tiempo

- ❖ Es juzgado prudencialmente por los Juzgado de comercio
- ❖ (*) Se ha agregado un elemento subjetivo de la costumbre, llamada *Opinio iuris*, es la convicción de que sea una regla de derecho.

El paso final para que la costumbre sea considerada una regla, debe ser probada en los términos del artículo 5 del Código de Comercio. No basta que concurren estos requisitos, sino que además la costumbre debe probarse para que sea considerada regla de derecho.

3.5.2. ¿Cómo se clasifica la costumbre?

a) Según su fuente formal:

- **Según la ley:** esta es la que refiere el Código Civil
- **Fuera de la ley:**
- **Contra la ley**

b) Según su función:

- **Interpretativa:** la costumbre cumple una función de interpretación. Está establecido en el artículo 6 del Código de Comercio. Sirve para interpretar los actos o convenciones mercantiles.
- **Jurídica:** consiste en crear una regla de derecho
- **Técnica:** Existen muchos conceptos técnicos. Es aquella que sirve para determinar el sentido o alcance de ciertas palabras o términos del derecho mercantil. Por ejemplo, en las operaciones de seguros, bancos y valores, existen ciertos términos que tienen una cierta particularidad, ya que se repiten constantemente.

Art. 6°. Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles.

c) En cuanto a su ámbito de aplicación:

- **Costumbre Nacional**
- **Costumbre Internacional o extranjera**

Una vez que tenemos este plano del derecho comercial, surge otro problema en donde existe confusión. Hay ciertas actividades, en las que algunos todavía creen que se puede aplicar la costumbre como fuente de derecho. Por ejemplo, en todos los negocios que ejecuta la banca, el retail, las grandes tiendas, **¿se podría argumentar que la costumbre es aplicable en los actos y contratos que ejecutan estas empresas? ¿Dónde está el límite?** R: PARA EL CONSUMIDOR NO. No se puede aplicar la costumbre con el consumidor, sino que solo en las relaciones contractuales entre comerciantes. Cuando no es así y estamos en presencia de un consumidor, se aplica la ley de protección al consumidor, tiene una ley en concreto.

Cuando abordemos el análisis de la ley de protección del consumidor. **¿Qué ocurre con la teoría del acto mixto en la ley de protección al consumidor?** R: Se deroga la teoría del acto mixto en la ley de protección al consumidor. Esto tiene mucha importancia porque finalmente, en ese caso, lo que le interesa al legislador, es identificar la relación de consumo. Hay que determinar si está completa la relación de consumo. Basta que se den los elementos de esta relación para que se aplique la ley de protección al consumidor, da lo mismo si hay comerciantes o no.

21 de marzo de 2018

¿La costumbre por sí sola, puede ser una regla formal de derecho en nuestro ordenamiento? **¿Invocamos la costumbre en los conflictos ante un tribunal? ¿Bastaría para que el juez lo considere como derecho objetivo y lo aplique en la sentencia?** R: la costumbre en el derecho mercantil, es “fuera de la ley”, es decir, completa o llena el vacío de la norma. La pregunta va más allá de eso, ya que siendo la costumbre de determinada manera y reuniendo los requisitos que la ley exige, ¿basta para que se considere? R: no, porque la costumbre debe probarse o acreditarse. Así lo establece el artículo 5 del Código de Comercio:

Art. 5°. No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por alguno de estos medios:

1°. Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella;

2°. Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba.

Debe acreditarse, salvo que sea un hecho notorio o sea conocida. Las formas de probar la costumbre pueden ser una u otra, u ambas si se quiere el éxito. Desde el punto de vista práctico, hay que preocuparse de probar la costumbre, ya que no hay que esperar que sea un hecho conocido (hay que ser precavidos).

Ahora que revisamos las fuentes del derecho mercantil **¿Cuál es su orden de prelación?:**

- ❖ La Constitución Política de la República
- ❖ El Código de Comercio
- ❖ El Código Civil
- ❖ Las leyes específicas
- ❖ Los tratados internacionales
- ❖ **Por último, la costumbre**

II.

EL CONTRATO MERCANTIL

En términos generales para identificar o precisar cuándo un contrato es mercantil, la doctrina chilena que está de alguna manera “amarrada” por la problemática del artículo 3 del Código de Comercio – y su teoría objetiva-, sostiene que para precisar o determinar la mercantilidad del contrato, se debe precisar si existe en ese contrato un acto de comercio que se pueda incorporar o incluir en el artículo 3 del Código de Comercio. Ricardo Sandoval señala que el contrato mercantil lo será cuando sirva de instrumento o medio para el desarrollo del tráfico y de un acto de comercio en concreto, que se opone a la doctrina que ha recogido una tesis subjetiva del derecho mercantil, centrada inicialmente en el comerciante y hoy día en la empresa y sus actos.

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1. ¿Qué es un contrato?

❖ R: Artículo 1437

Art. 1437. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad.

El contrato en el Código civil, **es una fuente de obligaciones**. Es un acto generador de obligaciones, un acuerdo de voluntades, desde el punto de vista de negocio jurídico. Se requiere entonces, para el nacimiento de las obligaciones, la concurrencia de dos o más voluntades.

❖ Artículo 1438, es un acto por el cual una o más partes se obligan para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Art. 1438. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

No hay gran diferencia entre el Código civil y el Código de comercio en materia de contratos. El concepto es el mismo. Hay, sin embargo, algunas concepciones doctrinales, sobre todo aquellas que están más bien vinculadas al análisis económico del derecho, que definen el contrato como expresiones voluntarias que sirven como instrumento del tráfico mercantil. Richard Posner dice que “solo requieren ser regulados por el derecho, en el incumplimiento”.

“Destacamos la importancia de los intercambios voluntarios y la transferencia de usos menos valiosos a usos más valiosos y señalamos diversos obstáculos para los intercambios maximizadores del valor. La razón por la cual se justifica la **regulación del contrato, está fundamentalmente representada por la contingencia del incumplimiento**”

Hace muchos años, Raúl Lecaros tomó una expresión bastante evidente: **¿Si usted contrata, para qué lo hace?** En el derecho continental se entiende que es para el cumplimiento, y no al revés. Esa visión, es una visión correcta y distinta de la de los manuales. Cuando se celebra un contrato, se contrata para satisfacer un interés concreto. No se celebra un contrato para provocar de manera negligente un vicio de consentimiento que podría acarrear una nulidad del contrato. **Lo importante es cumplir, por lo que el legislador ha ido incorporando una serie de normas en el ordenamiento, que apuntan a mantener viva la relación contractual**, evitando problemáticas de ineficacia o nulidad en el negocio jurídico en general. Esta es la visión moderna. Hay que incorporar cláusulas que busquen la satisfacción de las partes, este es el objetivo del abogado. Hay proyectos que se están ejecutando en materias de contratos de construcción, porque tiene una característica de susceptibilidad a conflictos increíble. Para esto, se están realizando marcos contractuales para evitar estos conflictos.

Como este contrato mercantil en su estructura y concepto, no difiera del contrato civil **¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para que podamos argumentar que estamos en una figura contractual?** R: para que exista un contrato debe haber voluntad, objeto y causa. Luego hay que especificar, si la voluntad está exenta de vicios, objeto lícito y causa lícita. También se le agregan la capacidad (relacionada con la voluntad) y las solemnidades (medio por el que se exterioriza la voluntad. De aquí la distinción entre contratos solemnes y contratos consensuales) para aquellos casos en que la ley lo exige.

2. DIFERENCIAS ENTRE UN CONTRATO CIVIL Y UNO MERCANTIL

Luego, hay algunas diferencias entre el contrato mercantil y el contrato civil –no desde el punto de su concepto, estructura ni como se forma el conocimiento-, principalmente referidas a:

- **Formas de cumplimiento o ejecución (y dentro de esto, dos elementos: plazo y pago)**
- **Hay pruebas del contenido del contrato diferentes en ambos regímenes**
- **Hay diferencias en el régimen de responsabilidad, principalmente en la prescripción.**

En materia de obligaciones, si nos remitimos a la forma de cumplimiento o exigencia de cumplimiento: **¿Cómo las clasificamos?** R: las puras y simples y las sujetas a modalidad: plazo, condición o modo.

La obligación pura y simple, significa que se debe ejecutar de inmediato, se puede exigir el cumplimiento de inmediato. ¿A través de qué mecanismo puedo cumplir de inmediato una obligación? R: el pago o solución –es el modo más común de extinguir una obligación- que está regulado en el Código Civil en el título 14 del libro IV: **“De los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo”**. Art 1568 define pago: el pago efectivo es la prestación de lo que se debe y debe hacerse por regla general bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación (de acuerdo a lo pactado). Si la obligación es pura y simple, es de inmediato.

- a. **¿Existe alguna regla en nuestro Código de Comercio de carácter especial respecto de alguna modalidad? R: Si. Respecto del plazo como modalidad para el cumplimiento de la obligación. ¿Qué señala el Código de Comercio?**

R: el artículo 110 del Código de Comercio:

Art. 110. En la computación de los plazos de días, meses y años, se observarán las reglas que contienen los artículos 48 y 49 del Código Civil, a no ser que la ley o la convención dispongan otra cosa.

La regla general es lo dispuesto en el artículo 48 y 49 del Código civil, luego, a diferencia de lo que dispone el código civil, la legislación mercantil incorpora una regla de excepción: “La obligación que vence un día domingo, es pagadera al día siguiente” en su artículo 111. Bastante obvio, ya que ese día el comercio está cerrado. “La misma regla se aplica para los días sábados y para el 31 de diciembre de cada año”.

- b. **Otra de las reglas relacionadas con el pago, se relacionan con la imputación, especialmente cuando entre un mismo acreedor o deudor subsisten varias obligaciones.**

La facultad de imputar está en el deudor en el Código Civil y las normas del Código de Comercio disponen en el artículo 121 que “el acreedor que tiene varios créditos vencidos contra un deudor, puede imputar el pago a cualquiera de las deudas, cuando el deudor no hubiere hecho la imputación al momento del pago”. **La regla mercantil, pareciera que establece la regla inversa –que subsiste en el acreedor-, sin embargo, en la parte final del artículo 121, la facultad de imputar el pago subsiste en el deudor, pero solo al momento del pago**. Si nada dice el deudor una vez que materializa el pago, subsiste la facultad del acreedor de imputar el pago a cualquiera de las obligaciones vigentes entre ambos.

- c. **Otra de las diferencias importantes que existen, entre el contrato mercantil y el civil, está relacionada con la prueba del negocio mercantil o contrato mercantil (el contenido del contrato).**

La regla general, está establecida para todos los contratos, en el artículo 1708 y 1709 del Código civil. Establece una regla de prueba, en concreto de prueba testimonial y de procedencia de prueba testimonial. Es decir, si puedo o no probar el contenido de contrato por medio de testigos.

El Código Civil establece:

El artículo 1708 señala: “NO se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito”

El artículo 1709 señala: “Deberán constar por escrito los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM”

V/S

En cambio, el Código de Comercio establece:

El artículo 128 señala: “La prueba de testigos es admisible en los negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar”. La regla es distinta, salvo excepción en los casos en que la ley exija escritura pública (Cuando la ley exige escritura pública, la exige en la dimensión de solemnidad). Esto último tiene mucha importancia para entender el artículo

129, si no entendemos que exige escritura pública en el sentido de solemnidad, se nos produce un conflicto de normas.

Hay un elemento a adicionar: el que se exija escritura pública, significa que se exige solemnidad del acto o contrato. Esto que estamos refiriendo, tiene mucha importancia para comprender la razón y la lógica del artículo siguiente del Código de comercio (art. 129) Si no se entiende que la escritura pública es una solemnidad del contrato, se produce una confusión.

Artículo 129: “Los juzgados de comercio podrán admitir prueba testimonial, aun cuando adicione o modifique el contenido de las escrituras públicas (cuando la escritura pública no tiene el sentido de solemnidad)”

Aquí se refiere a que la escritura pública existente, no es solemnidad. Se pueden celebrar contratos que no son solemnes y se puede dejar constancia de este contrato en escritura pública (¿por qué? R: principalmente por la prueba, un instrumento público da seguridad). Un contrato puede ser consensual, pero se deja por escrito en escritura pública, principalmente por temas de prueba.

- d. **Artículo 126 del Código de Comercio:** no hay rescisión por causa de lesión enorme en los contratos mercantiles.
- e. **Finalmente, la regla de prescripción del artículo 822 Código de Comercio que establece un plazo especial:** “Las acciones que procedan de las obligaciones de que trata el presente libro (libro segundo) y que no tengan un plazo especial señalado en la ley, durarán –prescriben- 4 años. Es importante separar el plazo de prescripción en materia civil que son 5.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO MERCANTIL

Existen tres características unidas:

- (i) El dinamismo.
- (ii) La importancia del principio de la autonomía de la voluntad
- (iii) La particularidad de la innominada: cuando en 1867 entró en vigencia este código, podrían hacerse un listado gigante de estos contratos, que no están regulados en nuestro ordenamiento o que tienen una regulación dispersa. Muchos contratos nacen en la práctica mercantil y se innominan en la práctica mercantil. Hay una serie de transacciones que hoy en día son del tráfico mercantil, y que podemos calificarlos como tal.
- En la teoría moderno o más actualizada del derecho mercantil, los actos mercantiles están más vinculados a los actos de la empresa.
- Otra de las particularidades bastante importantes en el fenómeno del tráfico mercantil, es que se integran mediante condiciones generales. Hoy el tráfico de transacciones o transferencia de bienes o prestación de servicios en un volumen importante, está sustentado en condiciones generales de contratación (contratos predispuestos, formularios o pre elaborados por las partes)

Si es masivo sería de adhesión y de consumo. Si este contrato mercantil es masivo y de adhesión, sería de consumo, por lo que se regirían por la Ley de Protección al Consumidor.

En materias de la Ley de protección al consumidor hay reglas muy importantes en materias de formación de la relación contractual que se apartan radicalmente de las reglas de derecho común. En materia de Ley de Protección al Consumidor, **¿cuál es la regla que más se aparta en relación a la formación del consentimiento de la ley común?** R: Hace referencia al silencio. ¿Se le puede conferir al silencio el valor de manifestación de voluntad en la Ley de protección al consumidor o en una relación de consumo? R: No. En cambio, en el derecho mercantil si se puede (si es circunstanciado).

- **Tiene una vocación internacional:** esto es fundamentalmente porque hoy en día todos les compran a los chinos, por ejemplo.
- **Se celebran y ejecutan en soporte electrónico:** todas las transacciones casi, son electrónicas. Plástico para el metro, plástico para pagar, todo se compra por internet. **El contrato mercantil, es en todo o en parte en formato electrónico.** Esto tiene relevancia, ya que el hecho de que el contrato se celebre electrónicamente incide en la formación del consentimiento, ya que **¿es un contrato electrónico, entre ausentes o entre presentes?** Además, existe otro elemento importante: **la seguridad en el tráfico.**

Resumen: Este es el concepto del contrato mercantil, que no es otro más que el concepto de contrato general. Debe reunir todos los requisitos de validez de todo contrato y tiene ciertas reglas especiales en tanto mercantil (en materia de ejecución: plazos y pago, en materia de prueba: de admitir o no prueba testimonial, en materia de prescripción). Estas son las características que podríamos anunciar hoy en día del contrato mercantil.

III.

COMERCIO ELECTRONICO, FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y PROCESO NEGOCIADOR

Jueves 29 de marzo de 2018

1. COMERCIO ELECTRÓNICO

A raíz del comercio electrónico nos haremos dos cargos de dos temas importantes: **la formación del contrato/consentimiento y el proceso negociador.**

¿Cuándo puedo argumentar que estamos frente a un vínculo jurídico entre dos partes? R: esta es una línea delgada compleja, que debemos aprender durante esta unidad.

En el comercio electrónico, lo más importante es la incorporación propuesta de la ley modelo UNCITRAL. Uncitral es una especie de unidad dependiente de las Naciones Unidas que conforma distintas comisiones (especialmente en derecho comercial e internacional) y que tiene la función de presentar propuestas de leyes modelos. Hay distintas propuestas de leyes modelos que tienen un objeto o finalidad muy importante: que exista **uniformidad en principio en el comercio internacional y en el derecho globalizado.** Se quiere que este derecho vaya conforme al derecho comercial de los países a nivel interno. Es algo parecido a la Unión Europea, que el ordenamiento chileno tiene como fuente muchas veces las normativas del parlamento europeo. Este parlamento dicta normas de directivas sobre distintas materias y estas directivas tienen un plazo para que cada país incorpore directivas a su ordenamiento nacional (esto se llama superposición normativa).

Si revisamos, muchas de las modificaciones de los últimos años en nuestro ordenamiento, nos daremos cuenta que cuando nuestro legislador mira la legislación alemana, francesa, incorpora en nuestro ordenamiento estas directivas. Inglaterra tenía una posición bastante reticente a incorporar estas normas en su derecho vigente. Todo el esfuerzo doctrinal que se hizo en Europa durante tantos años, para crear uniformidad en normativa respecto de contratos, que llevó a Francia a derogar la "causa", terminó en nada.

Dato: La ley modelo Uncitral es importante ya que, en materia de arbitraje comercial internacional, nuestra ley es idéntica a esta última.

Esta ley establece que, frente a los problemas del comercio electrónico, se incorporen en las legislaciones nacionales, ciertos principios o reglas que están contenidas en la ley Uncitral:

- a) **Principio de equivalencia funcional**
- b) **Principio de neutralidad tecnológica**
- c) **Principio de inalteración del derecho preexistente**
- d) **Principio de Buena fé**
- e) **Principio de Libertad contractual**

Son principios o reglas que están contenidas en la ley modelo Uncitral para el comercio electrónico y son reglas que se recomiendan incorporar en los ordenamientos nacionales, cuando el Estado decida regular problemáticas del comercio electrónico.

La importancia del comercio electrónico es que sustituye el instrumento tradicional a través del cual se desenvuelve el proceso de contratación o el tráfico que es la voz y el papel, **por la inmaterialidad**. En base a esta definición, la doctrina ha señalado que el comercio electrónico provoca la desmaterialización del contrato. Entonces encontramos dos elementos vinculados a esta desmaterialización del contrato:

- Es **global**
- Es **virtual**

Ya no existe papel, ya no hay registro de voz, si no que un registro digital relacionado con el concepto virtual y además es global, ya que se le puede comprar a un individuo en cualquier parte del mundo.

Existe un autor que se llama Recalde que define el comercio electrónico de la siguiente manera: *en un sentido lato, por comercio electrónico entendemos los contratos en los que las declaraciones de voluntad negocial se emiten por medios electrónicos*. Cuando este autor se hace cargo de esta definición, califica esta situación como comercio indirecto. Este comercio no solo está contextualizado en las declaraciones de voluntad, sino que además en el cumplimiento del contrato.

¿Dónde por ejemplo puedo ejemplificar que en un sistema de soporte electrónico hay un cumplimiento de obligación? R: el pago o solución es el ejemplo más evidente. ¿Cuál es el modo más común de extinguir la obligación? R: el pago ¿Cómo pagamos hoy en día? R: con tarjetas principalmente.

¿Qué pasa con las boletas? R: en este caso es el recibo que acredita el pago y que está vinculado con una obligación tributaria. Aun así, la tendencia es que todo sea electrónico.

Entonces, estos elementos son muy importantes. **¿Cuál es la ventaja del comercio electrónico?** R:

- **La movilidad**
- **La celeridad**
- **La accesibilidad** (o transferencia de información): hay un acceso más fácil a información de la contratación de un servicio o de un bien concreto
- **La economía:** se supone que el comercio electrónico disminuye los costos de las transacciones, tanto para el empresario como para el consumidor.

Aun así, el comercio electrónico tiene ciertas desventajas jurídicas, vinculadas con tópicos muy concretos: **Es menos seguro jurídicamente, no hay certeza jurídica**. Este es el gran problema del comercio electrónico y esta seguridad jurídica en general está vinculada con problemas de formación del consentimiento. Tener certeza del momento en que se formó el consentimiento, la problemática de precisar si en el soporte electrónica estamos en presencia de formación del consentimiento entre presentes o entre ausentes. También hay poca certeza respecto del cumplimiento de ciertas obligaciones. No sabemos si el pago se hizo efectivamente y tampoco tenemos certeza de adquirir el producto que adquirí por el soporte y esto se puede traducir en una problemática de lesión de

derechos o del interés que me motivo a contratar. Por esta razón Uncitral ha tratado de buscar una fórmula para resolver el problema de la incerteza que se traduce en inseguridad jurídica.

Desarrollo de los principios:

- a) **La equivalencia funcional** quiere decir que el soporte electrónico que permite transportar los **mega datos (MD)** cumple la misma función que el soporte material y por tanto no se alteran los efectos del proceso. El soporte electrónico permite que los efectos del contrato sean idénticos a aquellos que se producen si yo contrato a través del sistema tradicional.

¿Nuestro legislador habrá reconocido en alguna norma el comercio electrónico? ¿Podremos encontrar algún artículo en nuestro ordenamiento en donde se reconoce este principio? R:

Hay un artículo en la Ley de Protección de los derechos del consumidor (ley 19.955) (el 12 A) que dice lo siguiente:

Artículo 12 A.- En los contratos celebrados por **medios electrónicos**, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquiera otra forma de comunicación a distancia, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos.

La sola visita del sitio de Internet en el cual se ofrece el acceso a determinados servicios, no impone al consumidor obligación alguna, a menos que haya aceptado en forma inequívoca las condiciones ofrecidas por el proveedor.

Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. Ésta podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor, el que se le indicará previamente. Dicha confirmación deberá contener una copia íntegra, clara y legible del contrato.

Entonces, la pregunta es **¿recogerá este artículo la regla de equivalencia funcional?** R: la equivalencia no es una analogía absoluta, lo importante es que la función o efecto sea el mismo. En los contratos celebrados por medios electrónicos, el consentimiento no se habrá visto formado si el consumidor no ha tenido previamente acceso claro a conocimientos claros sobre el servicio y haya tenido la oportunidad de almacenarlos o imprimirlos.

¿El legislador ha sido rígido en sostener este principio? Podemos concluir que sí reconoce este principio, al menos reconoce su función. A juicio del profesor, el legislador en el artículo 12 A reconoce el soporte virtual y si la reconoce y también reconoce su función, podemos llegar a la conclusión que, a través del soporte virtual, se puede producir el efecto del contrato.

Cuando dice: que le dé la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos **¿Qué le interesa al legislador?** R: buscar la certeza jurídica que la inmaterialidad no tiene. Pasar de una inmaterialidad a la materialidad al imprimir. Además, también busca la certeza al hacer que el consumidor se informe incluso antes de celebrar el contrato.

En la parte final del 12A dice que una vez perfeccionado el contrato, el proveedor tiene que enviar una confirmación escrita: que **también puede ser inmaterial (un correo, un mensaje de texto, etc.)**

Entonces, **se cumple este principio.**

- b) **Neutralidad tecnológica:** está relacionado –a través de la ley Uncitral- con recoger el dinamismo del comercio mercantil. Siempre hay genios que están creando nuevos soportes para desarrollar la postulación a través de sistemas virtuales. Lo que propone Uncitral es que el legislador no genere una especie de cierre de los medios.

Hay un artículo en el Código de Comercio en el que todavía existían las palabras de télex o fax. Entonces lo que propone la ley Uncitral es que exista una norma de reconocimiento genérico a los soportes electrónicos.

- c) **Inalteración del comercio pre - existente:** es un principio bastante utópico, que dice que la regulación del comercio virtual no altere la regulación nacional en materia de contratos. Pero finalmente en la práctica, ocurre que si hay una alteración del comercio existente. Ejemplos son los artículos 98 y siguientes del Código de Comercio (formación del consentimiento), la ley de protección al consumidor y otras normas, son hitos. Hay matices de diferencias importantes. Lo que plantea la doctrina es que no se altere la estructura de los contratos y la regulación de incumplimiento: los casos de nulidad, inexistencia y todos los remedios que están regulados en el cumplimiento contractual.
- d) **Principio de buena fe:** existe un reconocimiento en el comercio electrónico de este principio. ¿En qué consiste este principio?: La buena fé está reconocida en nuestro derecho en dos artículos 706 –“la conciencia de haber obtenido el dominio de una cosa por medios legítimos y exentos de todo fraude”- y el 1546 –“Los contratos deben ejecutarse de buena fé”. Efectivamente la doctrina distingue entre la buena fe objetiva y subjetiva. La buena fé subjetiva es la creencia de actuar conforme a derecho y la buena fé objetiva es una conducta de lealtad que deben respetar las partes en el proceso de ejecución contractual y que se integra como una regla más del contrato. Está integrada la buena fé en la relación contractual.

En la fase pre-contractual existen dos principios de acuerdo a 2 tradiciones del derecho (common law y civil law) Los sistemas del common law se rigen por un principio llamado *caveat emptor* que quiere decir que cada uno debe procurarse la información para contratar, no existe la buena fé. A diferencia de otros sistemas donde es fundamental.

- e) **Principio de libertad contractual:** es un principio de la autonomía de la voluntad que permite formular la libertad contractual y que se divide en el **impulso de la contratación** (contratar cuando quiero) y **en contenido del contrato** (contrato como quiero). En el comercio electrónico también debe ajustarse en la libertad contractual, especialmente en la dimensión del contenido, a ciertas reglas de protección que no hacen otra cosa que limitar o atajar esta libertad.

4 de abril de 2018

2. **FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL**

2.1. **Repaso de Derecho Civil**

Es importante tener claro cuando estamos en presencia de una relación contractual, para poder distinguir cuando estamos en presencia de un supuesto pre-contractual. Cuando vimos acto jurídico:

¿Qué es un contrato? R: Es un acuerdo de voluntades, un acto jurídico bilateral y como acto jurídico todo contrato requiere manifestación de voluntades. En nuestro Código civil tenemos una norma expresa que aborda que elementos deben concurrir para que estemos en presencia de un acto jurídico: este es el artículo 1445.

Art. 1445 Código Civil. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:

- 1º que sea legalmente capaz;
- 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio;
- 3º que recaiga sobre un objeto lícito;
- 4º que tenga una causa lícita.
- 5º (agregado por el profesor): solemnidades

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la

Sobre la base del artículo 1445 del Código Civil, la **doctrina elaboró la teoría o parte de la teoría del acto jurídico de todo aquello que está vinculado a la manifestación de la voluntad**. Cuando estamos en presencia de un contrato, estamos en presencia de una manifestación de voluntad de dos partes que deben ser capaces y con una voluntad exenta de vicios (error, fuerza y dolo).

a) Vicios del consentimiento:

- **Error:** es una falsa representación de la realidad. El error como vicio del consentimiento no está definido en el Código, sino que la doctrina lo define *como una falsa de representación de la realidad que arrastra a la parte a prestar su consentimiento*. La doctrina lo divide en error esencial, substancial, accidental. El error de hecho esencial u obstáculo vicia el consentimiento y trae como efecto la nulidad absoluta o la inexistencia para los que creen en esa teoría. El error substancial produce nulidad relativa y el error accidental también produce la nulidad relativa.

Para recordar:

Art. 1453 Código Civil. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra.

Art. 1454 Código Civil. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.

- **Fuerza**

- **Dolo**

- b) Debe existir un objeto lícito y causa lícita.

La no concurrencia de estos elementos referidos, acarrea un problema de eficacia estructural del contrato, nulidad relativa en un supuesto y nulidad absoluta en otro.

La nulidad absoluta y la relativa tienen diferencias (además del plazo). La nulidad absoluta se sana solo por el transcurso del tiempo y la relativa se sana además por ratificación.

(FIN REPASO CIVIL)

2.2. Oferta y Aceptación

La manifestación de voluntad en este contexto de bilateralidad de un contrato, exige necesariamente la concurrencia de dos actos previos: **la oferta y la aceptación**. *La oferta podemos definirla como un acto unilateral en que se propone a otra persona la celebración de un contrato. La aceptación es otro acto unilateral.* Si estos elementos concurren y además se cumplen los requisitos que señala la ley, entenderemos que se ha conformado el consentimiento en un contexto bilateral.

El proceso de formación del consentimiento, se encuentra regulado en el Código de Comercio en el artículo 98 y siguientes. El mensaje del Código ya nos advierte de dos problemas necesarios de resolver respecto de la formación del consentimiento: **la determinación del momento y del lugar donde se conformó el consentimiento**. Esto nos permite determinar la ley aplicable en la dimensión espacial y temporal.

En el mensaje del Código se señala:

En este mismo Título se trata de un asunto tan difícil como importante, omitido en la Ordenanza y aun en el Código Civil. Frecuentemente ocurre la necesidad de fijar el momento y el lugar en que las propuestas verbales o escritas asumen el carácter de contratos perfectos, y careciendo de reglas claras y precisas que dirijan el juicio del jurisconsulto e ilustren la conciencia del magistrado, es indispensable invocar las opiniones acomodaticias e inseguras de los autores que han examinado con más o menos profundidad esos puntos. Para obviar dificultades de tanta trascendencia, el Proyecto ha dado soluciones satisfactorias a las cuestiones principales e incidentes que ofrece la materia; y de este modo ha llenado un sensible vacío en nuestra legislación comercial y civil.

Es como si dijera: “Nos haremos cargo de la formación del consentimiento, ya que es importante la determinación del momento y del lugar”. En el comercio electrónico, la problemática del momento y lugar es un problema difícil de resolver.

2.2.1. Dicho esto, vamos a la oferta:

- **¿Qué requisitos debe cumplir la oferta de acuerdo a las exigencias de los artículos 98 y siguientes?** R: Que sea (i) **seria** y (ii) **completa**. Que sea seria significa que exista una verdadera intención de obligarse. Y que sea completa significa que debe contener todos los elementos de tal manera que la sola aceptación o conformidad del destinatario de la oferta

permita entender que estamos en presencia de la culminación del proceso de formación del consentimiento.

- **¿Qué tipos de oferta regula nuestro ordenamiento jurídico?** R: (i) una oferta hecha a persona determinada y (ii) oferta hecha a persona indeterminada. La distinción relevante está en que la oferta hecha a persona indeterminada no es vinculante, no obliga al oferente necesariamente de acuerdo a lo que señala nuestro. La pregunta es la siguiente, tenemos una norma –ley 19.496–, que se refiere expresamente a la oferta y es la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor: *oferta es la práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados que en forma transitoria en relación con los habituales y respectivos establecimientos*. Este concepto de oferta de alguna manera difiera del concepto de oferta que se elaboró por la doctrina y del Código de Comercio.
- Luego **¿Qué señala nuestra jurisprudencia respecto de la oferta?** R:

Cabe señalar que como es sabido, para que se produzca como resultado el acuerdo de voluntades el efecto jurídico de crear una o más obligaciones, es necesario que culmine un proceso tendiente a la formación del consentimiento mediante el concierto de dos actos jurídicos unilaterales e independientes, derivados, uno de aquel que toma la iniciativa y le propone a otro un negocio y este que es aquel al cual va dirigida la oferta que acepta la petición con su consentimiento. La yuxtaposición de estas declaraciones de voluntad mediante la convergencia de la oferta y la aceptación, dan lugar al consentimiento y con ello al contrato. En particular, la oferta es un acto jurídico unilateral mediante la cual una persona propone a otra una determinada convención y como acto jurídico, la oferta debe cumplir los requisitos de existencia y de validez que establece la ley, por lo que esta ser sería (producir un efecto práctico sancionado por el derecho) y también completa y precisa. Solo así, una vez que sea aceptada permite colegir la formación del consentimiento, dando lugar a la celebración del contrato.

2.2.2. Vamos con la aceptación:

La aceptación es el segundo acto que debe concurrir en conjunto de la oferta para la celebración del contrato. ¿Qué requisitos reúne la aceptación? R: (i) debe ser pura y simple, (ii) realizarse en el momento oportuno, es decir, que la oferta se encuentre vigente.

El oferente puede retractarse u arrepentirse de la oferta que ha emitido y ¿Cuándo? R: El artículo 97 del Código de Comercio dispone lo siguiente: *El proponente puede arrepentirse entre el tiempo medio entre el envío y la aceptación*. Formado el consentimiento, **¿opera o no la retractación?** Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (artículo 1545 del Código Civil). ¿Esto quiere decir que es fuente del derecho objetivo? No. Sino que significa que es obligatorio, es el pacta sunt servanda. No se puede retractar porque se está vinculado a esa persona y **solamente me puedo desvincular a través de las causales genéricas que establece el artículo 1545 del Código civil que dice que todo contrato es una ley para las partes y no podrá ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales**.

Debe ser pura y simple y oportuna, ya que el oferente puede arrepentirse en el tiempo medio del envío de la oferta y el tiempo de la contestación. **Salvo que** al haberla hecho se hubiere comprometido a esperar la contestación y a no disponer del objeto del contrato sino después de desechada la oferta o transcurrido un determinado plazo (Excepciones del artículo 99 del Código de Comercio).

Hecha la oferta, no existiendo aceptación, el proponente puede arrepentirse y en base a eso, la doctrina ha enunciado o definido la **retractación tempestiva y la retractación intempestiva**. La intempestiva (según no el profesor no debería existir, sino que se produce una responsabilidad contractual). Es tempestiva si se retracta conforme al derecho.

¿Qué efectos provoca la retractación tempestiva? R: Se analizará –más adelante- si una retractación tempestiva no produce efecto ninguno y si cuenta con tal nivel de tolerancia del derecho efectivamente que podría retractarme siempre en una fecha formulada sin que acarree ninguna consecuencia. El profesor adelanta que si hay o puede haber consecuencias cuando nos retractamos tempestivamente y estas están relacionadas con el proceso de negociación y todos los gastos en los que puede haber incurrido para llegar a ese momento de formulación de la oferta.

Cuando se acepta e incorpora nuevas condiciones a esa aceptación, estamos en presencia de una contraoferta. La aceptación condicional será considerada como una nueva propuesta (Artículo 102 del Código de Comercio).

Otro de los tópicos muy importantes que debemos tener en esta materia, es **la forma de la aceptación**. La aceptación puede ser (i) **expresa** o (ii) **tácita**. *Cuando es tácita se entiende que de ciertos actos se entiende inequívocamente que esa persona manifestó su voluntad en conformidad con la oferta que ha recibido.*

Aquí nos referimos a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor: ¿Qué ocurre o que norma podemos encontrar en la ley del consumidor que está relacionada con el acto jurídico unilateral de la aceptación? R: Art. 3 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor letra a): El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo. El problema que se ha generado desde el fallo Cencosud, es cuál es la línea divisoria entre el silencio y la aceptación tácita. En estas relaciones de consumo se entendería que la aceptación tácita no serviría o no sería tolerada. Pareciera que la Corte Suprema en el fallo Cencosud entendió que la aceptación tácita de la voluntad se asimila al silencio por lo que queda excluido como forma de aceptación y no obliga.

2.3. Problemática de la determinación del momento en el cual se formó el consentimiento:

Hay 4 teorías en la doctrina:

- **Teoría de la declaración:** se forma el consentimiento cuando el aceptante declara aceptada la oferta.
- **Teoría de la expedición:** se forma cuando destinatario que acepta, envía su declaración de aceptación al oferente
- **Teoría de la recepción:** cuando el oferente recibe la aceptación del aceptante
- **Teoría del conocimiento:** el consentimiento se forma cuando el oferente conoce la aceptación.

Esto tiene relevancia cuando el contrato es entre ausentes, ya que entre presentes no tiene importancia. Art. 97: “Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirige; y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso”. La problemática del momento de la formación del consentimiento es entre ausentes. En este supuesto la doctrina ha señalado (Víctor Vial) que **nuestro derecho recoge la teoría de la declaración**.

La determinación del momento y del lugar de la formación del consentimiento, tiene importancia para determinar la norma aplicable.

- Cuando nos referimos a la contratación mercantil, desde el punto de vista temporal o de tiempo. **¿Qué norma se aplica?**: R: la del momento de contratación. Esto es muy importante, ya que las reglas pueden cambiar. Luego de la celebración de un contrato pueden dictarse leyes que regulen ese contrato de una forma diferente, pero debido a la ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, los actos y contratos deben regirse por las leyes del acto en que se celebraron.
- **Lo mismo ocurre respecto del lugar**, ya que nos regiremos por las normas del lugar. Si celebramos un contrato en la Zofri de Iquique entre comerciantes, puede regirse el contrato por una costumbre local, distinta de la que rige en Santiago, por ejemplo. La determinación del lugar de donde se celebró el contrato, es fundamental. Residiendo los contratantes en distintos lugares, **se entenderá celebrado el contrato para todos los efectos legales en el de la residencia del que hubiera aceptado la oferta primitiva o la propuesta modificada**. Esto es complicado cuando los que contratan residen en distintos lugares y quieren decidir en donde se regirá el acto. Esto también es un problema en las personas jurídicas y sus sucursales.

¿Y que sucede con el comercio electrónico? R: Existe una problemática de la formación del consentimiento en el contrato electrónico. **Se entiende ¿entre ausentes o entre presentes?** ¿Todas las tecnologías con soportes virtuales a través de las cuales se desarrolla la formación del contrato pueden considerarse entre presentes o entre ausentes? **Estas respuestas las encontraremos primeramente en el texto de Ruperto Pinochet.**

5 de abril de 2018

Texto de Ruperto Pinochet: Respecto a la formación del consentimiento en el contrato electrónico.

1. Problema que plantea: si es entre presentes o entre ausentes

Solución: Pinochet, plantea algo respecto del comercio electrónico y las teorías, se basa en la teoría de la recepción. Ajusta su planteamiento a esta teoría. Es la que logra captar todos los elementos (más desarrollada) y mejor se adapta.

¿Se puede argumentar normativamente el que rija la teoría de la recepción en vez de la de la declarativa? Sí, en la Convención de Viena para la compraventa internacional de mercaderías (que es norma vinculante por estar ratificada por Chile).

Uno de los principios de la ley Uncitral se llama de equivalencia funcional (el desarrollo de las distintas tecnologías permiten ajustarlo a la inalteración del derecho preexistente). Pinochet busca una fórmula para que ambos principios se armonicen (inalteración y equivalencia funcional).

¿Cuándo es entre presente y entre ausente? se basa en si hay intermediación e interrupción en la comunicación. Ej: carta y llamada.

Ahora, nosotros analizamos. **¿Qué pasa si llegamos a la conclusión finalmente que todos los sistemas tecnológicos estamos en un contexto de contratación entre presentes (ya que a varios de los sistemas los cataloga como entre presentes)?** Entonces, en ese momento ¿se formaría el consentimiento?

2. Críticas a texto de Pinochet:

¿Para qué la doctrina se hace cargo de esta problemática, en qué casos? Del momento o del lugar. Las teorías que utilizó y que abordan la problemática de formación del consentimiento fueron elaboradas en el contexto entre ausentes, no entre presentes. Pero, ¿entonces por qué no aplica la norma de entre presentes que está en el código?

Cuando es entre presentes no debiera haber ningún problema al determinar el momento de formación del consentimiento. Si estamos en un contexto entre presentes, ¿por qué aplicamos una teoría de entre ausentes? Desde esa perspectiva también es cuestionable que en el comercio electrónico entendiéramos que hay un contexto de contratación entre presentes.

Profesor: Según el profesor la respuesta a si estos medios son entre presentes o ausentes, está en la simultaneidad y en la ininterrupción de la comunicación, de ser así estamos frente a una contratación entre presentes.

10 de abril de 2018

La mercantilidad del contrato tiene una gran importancia **pues así se determina la normativa aplicable**. Una vez que se revisan las fuentes, revisamos el concepto del derecho mercantil y dentro de este concepto, verificamos la teoría objetiva y subjetiva y criticamos la objetiva. Esta crítica hizo enumerar ciertas teorías respecto del comerciante, que implican que hoy, el centro o el núcleo no se encuentra en el código de comercio, **sino que principalmente en la empresa**. La empresa tiene su origen previo en la teoría de los actos en masa. La doctrina observó la realidad y se dio cuenta que el desarrollo del tráfico estaba muy ligado a un nuevo fenómeno que eran los actos en masa. Esto provocó cambios en los fines y visión del derecho mercantil que se tuvieron en cuenta cuando se inicia el proceso de codificación francesa de 1807.

Esto es importante, porque lo que se empezará a estudiar hoy está íntimamente vinculado con las problemáticas de deberes de información en las tratativas preliminares. Luego de hablar de los deberes de información en los tratos previos, se tratará otro tema fundamental que son las condiciones generales de contratación.

3. DEBERES DE INFORMACIÓN EN LAS TRATATIVAS PRELIMINARES / PROCESO NEGOCIADOR

¿Dónde se ubican los deberes de información y las tratativas preliminares en el proceso de formación del contrato? El estudio de la formación del consentimiento, nos permite precisar si hay o no hay contrato. Todas las reglas sobre formación del consentimiento confluyen en esta idea central: hay o no contrato ¿Existe un vínculo jurídico entre dos o más personas? Esto es importante ya que hay muchos procesos en la actividad mercantil que son tremendamente complejos y en estos procesos hay que ser muy cuidadosos en la determinación del vínculo, porque este es ley para las partes. **Se tiene que tener claro cuándo o en qué momento se genera este vínculo jurídico, ya que creado este vínculo jurídico se produce la regla del “pacta sunt servanda”**. Incluso podemos hacer un ejercicio hacia atrás. Hay que tener en claro los elementos o requisitos que deben tener los actos jurídicos unilaterales que forman el contrato. La oferta debe ser: seria y completa. Si se detecta en un proceso de negociación compleja, que esta no es seria o no es completa, no hay contrato.

3.1. Concepto y evolución histórica

De acuerdo a la teoría tradicional, el proceso de formación de contratos, están sustentados en el principio de autonomía de la voluntad. Esto implica o contiene dos subprincipios:

- La libertad contractual en cuanto **a la determinación del contenido del contrato**
- La libertad contractual en el **impulso de la contratación**.

Se contrata con quien quiero, como quiero y cuando se quiere (se partía de la base de una relación simétrica). En el principio del proceso de contratación moderno (fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, conectado con los actos en masa), los legisladores detectan que existe una **problemática de desequilibrio o desigualdad en la posición entre las partes**. Por consiguiente, se incorporan en los ordenamientos jurídicos deberes de información. Estos deberes de información podemos además clasificarlos en varios tipos de deberes:

- **Típicos:** *son los deberes de información que están expresamente regulados por el legislador, se impone a ambas partes la entrega de información y además se preocupa de precisar qué tipo de información debe entregar.*

Por ejemplo, en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor el proveedor –por regla general- debe entregar cierta información básica comercial (predeterminado por el legislador). Otro caso más reciente es el contrato de seguro, donde el legislador impuso al asegurador entregar -durante el proceso de formación del contrato- cierta información precisa o clara al asegurado o consumidor.

- **Atípicos:** *se da en todos aquellos supuestos en los que, no existiendo un deber de entrega de información consagrado en la ley, debe uno de los contratantes entregar información al otro. La buena fe obliga (dimensión objetiva) obliga a entregar información al otro contratante sobre el contenido del contrato. Debe ser un suministro de datos sobre el contenido contractual.*

3.2. Buena fé en los deberes de información

Aquí hay un punto importante de diferencia radical entre el civil law y el common law. En los ordenamientos del common law se rigen por el principio bastante opuesto al nuestro (*caveat emptor*). Los ingleses como son piratas, creen en el **dolo bueno al extremo**. Ellos comercian de esa manera. Es una forma de pensar muy distinta. Cuando les hablan de buena fé no existe en ese sentido, cada uno debe proveerse de la información necesaria para contratar.

Nosotros nos regimos por un principio bastante utilizado: la buena fe que ha llegado a sostener que hay que entregarle a mi contraparte toda la información necesaria para tomar una decisión consciente, libre e informada. nn

En el comercio en general se acepta el dolo bueno (esa artimaña del comerciante para obtener una mayor ventaja). Pero cuando existe un engaño esto no va. Esto depende del tipo de contrato y de los contratantes. Si se están entre contratantes en una relación simétrica (ambas partes tienen información y situación económica equivalentes) los efectos de la buena fe se morigeran. Pero cuando una de las partes se encuentra en una posición mejorada respecto de la otra, termina sucediendo que una tiene más información que la otra y está en desventaja, por lo que requiere más información.

El principio de buena fe no es una regla absoluta y transversal, sino que en el caso a caso se debe ver en la situación en la que nos encontramos, si es una relación de igualdad o desigualdad. En esta perspectiva, los deberes de información, constituyen o producen dos efectos: (i) Un atajo/límite al principio de autonomía de la voluntad y (ii) una renuncia a una posición de ventaja.

3.3. Justificación de los deberes de información

Entonces la pregunta es **¿Qué justifica la imposición de deberes de información?** R: (i) **el fenómeno de la contratación estandarizada** y (ii) **las problemáticas de simetrías de la información**.

Cuando estamos en una posición de equilibrio, es necesario que se entregue la información, pero estará morigerada la obligación de este deber (por la buena fé). Cuando se encuentra una situación de desequilibrio o asimétrica (vinculado al fenómeno de la contratación estandarizada) existe un deber de información claro y el contenido de este deber llega al extremo del contenido del contrato de manera íntegra. El legislador ha entendido que existen dentro de estas problemáticas, una problemática de asimetría.

La contratación estandarizada permite superar el problema de la imposibilidad de sentarse a negociar cada contrato con un servicio. La mayoría del comercio se realiza de esta forma. En esta relación precontractual, contractual y posterior, claramente existe una relación asimétrica. No solamente porque la empresa esté en una situación económica mejorada con respecto al contratante, sino que además posee mucha más información que este último (sabe cómo es su producto, lo que necesitan los clientes, etc.)

El primer señor que se dio cuenta de esto fue G. RIPERT. Él se dio cuenta que las normas que se tienen en el Código Civil para proteger una situación asimétrica: era el caso de los incapaces. Advirtió que se daban supuestos de desigualdad. Esto se resolvió con que se actuara mediante representante. Las normas que regulaban el tráfico de inicios del siglo XX era insuficientes para proteger al consumidor (que está en una posición de desventaja). **Una de las formas mediante las cuales solucionó esto fue la incorporación de normas o instrumentos de tutela en favor de una de las partes.** Esto permite un reequilibrio en la medida de lo posible en esa situación contractual tanto en la fase de formación del contrato, como en la fase de ejecución/cumplimiento del contrato.

¿En qué momento surgen estos deberes de información? R: esto es un problema, ¿en qué momento yo estoy obligado a cumplir con un determinado deber de información?

En la doctrina alemana que la del origen de estos deberes, se sostiene que cuando existe un contacto entre dos partes de carácter negocial que advierte una intención inicial de celebrar un futuro contrato, en ese caso, existe una relación jurídica preparatoria que impone a los contratantes este deber de información. **En nuestra doctrina, ENRIQUE BARROS sostiene que, a diferencia del sistema alemán, nosotros no tenemos sustento normativo para afirmar que existe esta especie de relación jurídica preparatoria.**

Como no podemos traer la doctrina alemana a nuestro ordenamiento, **¿en nuestro ordenamiento, jurídico como podemos despejar o precisar que existe un deber de informar?** En nuestro ordenamiento no hay sustento normativo para incorporar esta doctrina. La respuesta es que el

legislador chileno se ha ocupado de imponer deberes de información –especialmente en el contexto de la ley del consumidor- de forma precisa, es el legislador el que recoge la exigencia de la buena fe y la incorporó en un artículo concreto normativamente. En el ordenamiento alemán, creen en la relación pre-contractual, en cambio, nuestro ordenamiento no lo recoge.

El otro elemento que me permite determinar cuando existe una obligación de entregar una información además de la buena fe, es la ley. Y otro elemento son los deberes de información atípicos, en que la buena fé objetiva impone deberes de información, lo que se determinará por el juez caso a caso si se cumplió un deber de información.

Este proceso de formación del contrato, esta contextualizado en la precontractualidad y que está integrado por estos deberes de información que tienen por objeto poner un límite a la autonomía de la voluntad. Conlleva también a la problemática de la responsabilidad que puede originarse dentro de este proceso.

La responsabilidad que puede surgir en el proceso de la formación del contrato –en esta fase precontractual-, **se identifica más propiamente en proceso de complejos de contratación**, esto porque para que podamos reconocer un supuesto de responsabilidad y de responsabilidad civil en particular, es necesario despejar cada uno de los elementos que nuestro ordenamiento jurídico exige para que estemos frente a un supuesto de responsabilidad y uno de ellos ha sido considerado por la doctrina como central. **¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad?**

Anexo: Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico en **dos estatutos**:

- Expresamente en los artículos 2314 y siguientes a propósito de los efectos que provocan las comisiones de los delitos y cuasidelitos civiles, esto es lo llamado **responsabilidad civil extracontractual**.
- Luego el estatuto de los artículos 1545 y siguientes que trata el derecho de obligaciones (y dentro los contratos) y que se ocupa de regular **la responsabilidad civil contractual**.

La responsabilidad civil se ocupa del daño y de precisar y determinar en qué casos hay daño y bajo que supuestos quien ha sufrido un daño debe ser reparado por ese daño que sufrió. Cuando existe un vínculo jurídico entre dos partes, la celebración de este contrato válidamente celebrado produce obligaciones para las partes. Cuando el incumplimiento de la obligación acarrea un daño o perjuicio para una de las partes, podríamos estar en uno de los supuestos de la responsabilidad contractual.

Y para determinar un supuesto de responsabilidad contractual debemos hacer un checklist:

- a) Un vínculo contractual.
- b) Una conducta que importa el incumplimiento contractual de una obligación.
- c) Que ese incumplimiento de la obligación sea imputable a culpa o dolo del que incumplió la obligación.
- d) Que exista un daño. Si no hay daño no hay responsabilidad.
- e) Que exista una relación causa-efecto entre el incumplimiento y el daño que sufrió una de las partes. Es decir, entre la conducta del deudor que le cause daño al acreedor.

¿Qué ocurre cuando frente a un supuesto de daño, no hay una relación contractual o un vínculo que no me una? R: aquí estamos frente a una responsabilidad extracontractual. Nuestro ordenamiento jurídico contempla un deber general de cuidado 2314 del Código Civil, de **desplegar una conducta diligente con el objeto de evitar causa daño a otro**. Los romanos la llamaban responsabilidad aquiliana, bajo el principio de *“alterum non laedere”* o no dañar a otro.

En responsabilidad extracontractual debe concurrir:

- a) Una conducta contraria a derecho (antijurídica)
- b) Que esa conducta sea imputable a dolo o culpa del quien ejecutó la conducta
- c) Que exista daño
- d) Una relación de causalidad o de causa efecto entre la conducta del individuo y el daño sufrido por la víctima.

Termino de anexo

¿Dentro de un proceso de negociación se puede dar un supuesto de responsabilidad que obligue a una parte a reparar el daño sufrido por la otra? La gran diferencia que existe en nuestro ordenamiento jurídico respecto del sistema alemán, es que nuestro ordenamiento no reconoce el régimen de responsabilidad pre contractual, sino que solo reconocemos el contractual y el extracontractual.

El desafío entonces es, **¿en un proceso de negociación existiendo daño en que una de las partes que participa en este proceso de negociación sufre daño, en que supuesto de responsabilidad estamos?** ¿contractual o extracontractual? Estamos en responsabilidad extracontractual. No existe la responsabilidad civil pre contractual como estatuto/régimen reconocido en nuestro derecho. Por lo tanto, en todos aquellos supuestos en los que en un proceso de negociación una de las partes sufre daño, **estamos frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual**.

Hay otro dato importante que hay que tener en cuenta, esto es, hay diferencias importantes entre la responsabilidad contractual y extracontractual:

- **El plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios** por responsabilidad contractual es de 5 años y en el caso de la responsabilidad extracontractual es de 4 años. Cuando existe un supuesto de daño hay que despejar si existe vínculo y si existe contrato. Además de ver si existe contrato, hay que ver qué tipo de contrato es. Existen ciertos tipos de contratos que tiene prescripciones de distinto plazo (como el contrato de transporte). **Si estamos en un contrato mercantil, el plazo de prescripción es de 4 años.**
- **El régimen de culpa.** En el régimen contractual el legislador reconoce un régimen de culpa graduada: leve, levísima y grave. La regla general es la culpa leve. Además, unida a esta graduación de la culpa -que tiene importancia porque hay contratos en que se rigen por otro régimen de graduación de culpa- en el régimen de responsabilidad contractual hay una presunción de culpa que pesa en deudor (cuando el deudor incumple, se presume que es culpable). Este régimen de culpa (ni presunciones ni gradualidad) no se da en la

responsabilidad extracontractual, pero si existen presunciones de culpa específicos en materia de responsabilidad extracontractual. No es la regla general como en materia contractual a raíz del artículo 1547.

La próxima clase se revisará el proceso negociador y se verificará si se pueden dar supuestos de daño dentro del proceso de negociación y si dentro de estos supuestos podemos invocar algún régimen de responsabilidad: adelantamos que es el extracontractual. Pero en el proceso negociador, nuestra jurisprudencia y doctrina han incorporado ciertos requisitos que parecieran ser adicionales a estos requisitos generales de la responsabilidad extracontractual.

11 de abril de 2018 (recomiendo estudiar de los textos en sí, esta transcripción es en base a lo que se contestó en clases)

Anexo: Clase de textos

El profesor nos entrega dos textos: uno de ENRIQUE BARROS y el otro de ALESSANDRI. Uno está escrito a una tesis más moderna de la responsabilidad y otro adscrito a una doctrina más tradicional de la responsabilidad.

BARROS habla de las diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Lo primero que plantea BARROS es que existe una gran división.

ALESSANDRI hace la distinción entre la contractual y la cuasi delictual y delictual. En la contractual hay un vínculo jurídico previo y con el incumplimiento se genera la responsabilidad. En el caso de la delictual y cuasi delictual no hay vínculo previo, sino que hay un hecho que engendra la responsabilidad delictual o cuasi delictual civil.

¿Qué problema acarrea esta división entre responsabilidad contractual y extracontractual? ¿Hay alguna crítica a esa distinción? ¿Se hace cargo BARROS de alguna propuesta que tienda a eliminar esta especie de distinción de Gayo?

ALESSANDRI hace una especie de paralelo entre ambos regímenes de responsabilidad:

- **Capacidad:** en materia contractual se tenía que tener 25 años para contratar. La distinción que se hace va relacionado al discernimiento de la persona y que es mucho más importante en materia contractual que en régimen de delito o cuasidelito civil.
- **Graduación de la culpa:** en materia contractual si admite graduación y no siempre la culpa logra incurrir en responsabilidad. En materia de delito y cuasidelito no admite graduación y toda falta engendra responsabilidad
- **Constitución en mora:**
- **Extensión de la reparación:** en materia delictual y cuasi delictual es completa y en materia contractual es solo a partir de prejuicios que se previeron o se pueden prever.
- **Facultades de los jueces para fijar los montos de la reparación:** según la jurisprudencia es aplicable en materia de delitos (no todos) y en materia contractual se va a litigar sobre el monto y la especie sobre la que se va a responder.

- **En materia de solidaridad:** La solidaridad es una modalidad. Si un delito y cuasidelito es realizado por dos o más personas responden solidariamente, en cambio en la responsabilidad contractual no responderán solidariamente a menos que así se haya estipulado.

¿Por qué en la responsabilidad extracontractual se estima como solidaria y en la contractual no? R: La solidaridad en términos generales es un mecanismo de constitución de la deuda. Cuando hay varios deudores el pago íntegro de uno extingue el total de la deuda. Cuando hay un acreedor en la responsabilidad extracontractual desde el punto de ser víctima y hay varios deudores o autores que cometieron el daño, puede ese acreedor o víctima ir en contra de cualquiera de los deudores por el hecho que le causó daño por el total de la deuda. **La regla general en materia extracontractual es la regla general, en cambio en materia contractual es la excepción y solo existe cuando se pacta** (recordar fuentes de la solidaridad: convención).

Tarea: Estudiar textos de ALESSANDRI Y BARROS Y estudiar texto en la parte de HERNÁN CORRAL y el tratamiento que hace ABELIUK (Tomo I o Tomo II del Manual obligaciones) que tiene una parte en donde hace un paralelo entre responsabilidad contractual y extracontractual.

17 de abril de 2018

4. TRATATIVAS PRELIMINARES, LA RESPONSABILIDAD IN CONTRAHENDO O PRECONTRACTUAL

La discusión doctrinal en materia de responsabilidad civil precontractual se ha centrado fundamentalmente en los siguientes tópicos.

La problemática de la responsabilidad contractual tiene su origen en la teoría de IHERING de la culpa in contrahendo. Se preocupó de la problemática que acarrea la invalidez del contrato Y los efectos dañosos que puedan tener las partes, particularmente respecto de los que tenían una expectativa de validez del contrato. Aquí se configura la figura del error y sobre esa base desarrolló la teoría de la culpa in contrahendo.

Los alemanes en su Código Civil en el BGB, recogieron expresamente la tesis de IHERING sobre la culpa in contrahendo en el párrafo 122 y este dispone lo siguiente bajo el título “Deber de resarcir el daño por aquel que impugna”: *“Si una declaración de voluntad es nula por el párrafo 118 –es decir, por falta de sinceridad- o ha sido impugnada conforme al párrafo 119 y 120 –es decir, por error o por remisión incorrecta que acarrea error- y debía ser emitida frente a otro, el declarante debe resarcir a este otro el daño sufrido”*. Es decir, la doctrina de alemana IHERING sobre la culpa in contrahendo y de la responsabilidad precontractual derivada del error, fue acogida expresamente en el párrafo 122 del BGB o Código Civil Alemán.

¿Podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico alguna fuente normativa que permita argumentar que hay supuestos de culpa in contrahendo que da lugar a la responsabilidad precontractual? Esto es muy importante, porque en el último tiempo hemos podido observar ciertas doctrinas chilenas que elaboran ciertas tesis y que no tienen cuadro normativo en nuestro ordenamiento. Enrique Barros ha sido un gran crítico en este sentido.

En la doctrina alemana creen en una relación preparatoria y ellos entienden que hay una relación jurídica preparatoria que vincula de alguna manera a las partes y que puede dar lugar a un supuesto de responsabilidad sin más.

4.1. Los fundamentos de la responsabilidad precontractual.

Esta se puede observar en procesos de negociación más complejos. En general, podríamos sostener que problemas de **responsabilidad precontractual no se observan o se pueden encontrar en contratos de adhesión**. Esto no quiere decir que no se pueda dar un supuesto en un contrato de adhesión en que se pueda dar lugar a la responsabilidad in contrahendo, es decir, podríamos vernos enfrentados a un supuesto de nulidad de un contrato de adhesión y de esto puede derivar una problemática de responsabilidad y de una frustración para una de las partes.

Lo importante, es que cuando desarrollamos este ejercicio intelectual de interpretación de la norma de determinar si hay cabida en ese caso concreto para argumentar la existencia de responsabilidad, debemos detectar un elemento prima facie. Antes de expresar que “queremos demandar por un supuesto de responsabilidad precontractual” en el caso de –por ejemplo- una nulidad en el contrato que provocó una afectación de la otra parte, debemos tener en cuenta un elemento primordial.

Aquí hay que detectar un elemento prima facie para verificar la veracidad de la acción que se interpondría en ese caso, **esto es si efectivamente hubo daño para una de las partes**. En esta responsabilidad precontractual (que no se encuentra reconocida) se debe determinar si hay daño o no hay daño. Si no hay daño no hay nada que hacer y no hay responsabilidad.

Pregunta para poder sentarse a dar el examen: ¿Cuál es el primer elemento de la responsabilidad que debo considerar para el ejercicio de la acción de indemnización? R: EL DAÑO.

Esto es muy importante, ya que el ejercicio del análisis de la responsabilidad precontractual y tratativas preliminares, no tiene ningún sentido si no existe este elemento que acabábamos de enunciar. **Si no hay daño no le interesa al derecho.**

La responsabilidad precontractual en el proceso negociador está fundamentalmente caracterizada por este tipo de **actos, minutas, cartas de intención, preacuerdos, precontratos**. PPT: “En diversos documentos, comunicaciones escritas consideradas como *actos preparatorios que tienen por objeto completar un proceso negociador con una finalidad, esta es, lograr el cierre de un negocio que implica finalmente la celebración de un contrato*. Por lo tanto, es muy importante que la problemática de la responsabilidad contractual la ubicamos en el **periodo previo a la formulación de la oferta**.”

Todos estos son actos preparatorios son aquellos que ya hemos analizado a propósito de la formación del consentimiento. Es aquí donde está la habilidad del abogado para **no** formular una oferta en este proceso negociador, ya que es vinculante. La oferta es vinculante, por lo que si dentro el proceso de negociación se formula una oferta seria y completa, y si a esto sigue la aceptación por parte de la otra parte o destinatario, se forma el consentimiento. Por lo que estaríamos frente a la formación de un acto jurídico y habría un contrato que obliga a las partes. Ya no estaríamos en una problemática de responsabilidad precontractual, sino a una contractual.

Frente a esto, surgen una serie de interrogantes, que no están cien por ciento claras ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Estos procesos generan problemas respecto de la responsabilidad y por lo tanto se tiene que determinar y precisar si efectivamente hay supuestos de responsabilidad.

- **¿Puede un futuro contratante romper la negociación? R: Soy libre de retirarme de la negociación, pero es posible que esté ligado a responder por los gastos previos.** A esta respuesta, necesita agregarse el sustrato normativo.

¿Dónde está consagrada la potestad para poder retirarme cuando quiera del procedimiento negociador? R: En la autonomía de la voluntad de la que deriva el principio de libertad contractual.

Pregunta para poder sentarse a dar el examen: **¿En qué norma de nuestro ordenamiento jurídico estaría consagrado el principio de la autonomía de la voluntad del que deriva la libertad contractual? R:** está establecida en el artículo 1545 del Código Civil. A nivel Constitucional el 19 N° 21 se establece el principio de la libertad económica o la libertad de ejercer cualquier actividad económica (además en este artículo se encuentra consagrado el principio de subsidiariedad, que limita la actividad empresarial del Estado, ya que se necesitan ciertos requisitos como la creación de la empresa a través de una ley de quorum calificado).

- **¿Existe libertad ilimitada en la etapa precontractual para retirarse de ella en todo momento?**

Nuestro ordenamiento se basa en el artículo 1545 por el principio de libertad de contratación, lo por que se podría dar término al proceso de negociación por regla general. **¿Cuál es el límite? R:**

- El límite está determinado por la buena fé objetiva: se debe ser leal con la contraparte y cada paso que se dé en este proceso debe ir dirigido a sentar las bases para efectivamente celebrar el contrato, aunque en el camino decida retirarme. Pero no puedo desarrollar un proceso de negociación para obtener ventaja.
- El principio alterum non laedere (artículo 2314 del Código Civil de no causar daño a otro).

Estos dos principios son los que establecen el límite al retiro injustificado del proceso negociador. El principio de buena fé objetiva es muy importante, porque si yo inicio un proceso de negociación con una parte determinada y ese proceso se inicia con el objetivo de obtener información de esa parte para luego retirarme e irme a contratar con otro, **claramente hay una vulneración al principio de buena fé objetiva.** Si se detectara esto, y se entregan -en un proceso judicial de indemnización de perjuicios- antecedentes que le permitan llegar a la convicción al tribunal de que fue de esa manera, se podría llegar a obtener una indemnización por los gastos incurridos e incluso por otros ítems distintos de los gastos en los que incurrió durante este proceso de negociación.

Analizaremos algo que está algo más claro en la doctrina, que es el interés positivo y negativo en la determinación del quantum de la indemnización.

Un ejemplo: Imaginemos que somos una empresa extranjera y queremos aterrizar en Chile para desarrollar un negocio de retail. Vamos donde una empresa e iniciamos una negociación, pero previo a hablar con la empresa, ya había hablamos con otra empresa. La primera empresa va a entregar mucha información sobre su empresa y su innovación tecnológica. Entonces la empresa extranjera se

retira y contrata con Falabella (la otra empresa, con la que se había hablado previamente), añadiendo toda la innovación tecnológica para Falabella. Entonces, este es el asunto clave, ya que para demandar hay que **verificar el daño y poder probarlo**. Aquí podría demostrarse que la empresa si sufrió daño, ya que perdió una parte del mercado por la incorporación de innovación propia en otra empresa que era imposible que la alcanzara -en ese periodo corto de tiempo-.

- **¿Qué ocurre con los gastos incurridos por uno de los futuros contratantes en orden a la celebración del negocio jurídico particular?**

Nuestro ordenamiento jurídico solamente **contempla la posibilidad de demandar gastos** (en el artículo 100 del Código de Comercio), pero -además- la **doctrina ha fundado la posibilidad de argumentar la indemnización del interés negativo** que está fundado en la frustración de la invalidez del contrato, por lo que, si efectivamente es nulo un contrato o sencillamente no se celebró porque se frustró la celebración del contrato, se podría reclamar la indemnización de perjuicios no solamente por gastos, sino que por toda la pérdida de mi patrimonio que me provocó el retiro injustificado de la negociación o incluso la pérdida de ganancia o de utilidad que me hubiera implicado el desarrollo de esa negociación.

- a) **¿Qué se entiende por tratativas preliminares?**

Lo que debemos entender por tratativas preliminares es que son actos preparatorios en los que se encuentra **ausente el elemento volitivo que integra el consentimiento**. No hay una declaración unilateral de voluntad en los actos preparatorios y esto es lo que nos permite distinguir ese claro límite entre el acto preparatorio y la oferta.

4.2. Características del proceso negociador:

- a) **Se ubica en el iter formativo del contrato, previo a la oferta**
- b) **Ausencia del atributo volitivo o declaración de voluntad unilateral (oferta)**
- c) **Buena fé objetiva y libertad contractual:** tiene su sustento aquí.
- d) **Pueden tratarse de simple entrega de información, cartas de intención, preacuerdos, etc.**
- e) **Constituyen un medio de prueba del daño:** es importante ya que analizamos tratativas para determinar la responsabilidad in contrahendo por la ruptura injustificada.
- f) **Pueden constituir un medio de prueba de la voluntad de los contratantes:** en los contratos complejos y de adhesión donde hay entrega de información (especialmente de aquel que adhiere) puede esa documentación precontractual, ser un elemento primordial para probar la voluntad de los contratantes.
- g) **No hay vínculo jurídico contractual:** con contractual se refiere al vínculo jurídico que se busca en el proceso
- h) **El término injustificado (podría) generar un supuesto de responsabilidad extracontractual:** es extracontractual porque nuestro ordenamiento no reconoce un tercer estatuto de responsabilidad como sería la precontractual, sino que solo encasillamos esta responsabilidad en la extracontractual.

4.3. Ruptura o termino unilateral del proceso negociador

Esto siempre cuando concurra un supuesto de daño. La doctrina chilena reciente (MARCELO BARRIENTOS) ha entregado ciertos elementos que deben concurrir para que se pueda identificar un supuesto de ruptura injustificada que pueda derivar en responsabilidad precontractual, que es siempre extracontractual.

- ❖ **Confianza razonable entre las partes durante el proceso negociador:** está fundado en la buena fé objetiva. Cuando se inicia un proceso negociador, se produce entre las partes una relación de confianza razonable fundada en la buena fé objetiva. Una iniciación de una negociación solo con el objeto de recabar información para contratar con otro, vulnera esta confianza razonable dentro del proceso negociador. Esto vulnera ambos principios ya mencionados: **buena fé objetiva (art. 1546)** y **el deber general de no causar daño a otro (art. 2314)**.
- ❖ **Ruptura injustificada del proceso negociador**
- ❖ **Daño**
- ❖ **Relación o nexo causal entre el daño y la conducta que está representada por la renuncia unilateral.**

Si vemos estos requisitos entregados por BARRIENTOS, en base a lo que hemos visto ¿hay algún elemento que falte? R: La culpa.

Todos estos presupuestos son elaborados doctrinalmente para ir dando curso e ir aceptando la reparación de daños por un retiro injustificado del proceso negociador.

4.4. La indemnización:

En relación a las tratativas realizadas por una profesora española, existen dos intereses que podrían estar protegidos por el ordenamiento jurídico y estos intereses nos podrían otorgar la respuesta del quantum indemnizatorio. **¿Cuánto es lo que se debe indemnizar por un retiro injustificado del proceso negociador?**

- **Interés positivo:** está vinculado con el cumplimiento contractual, ya que la profesora lo plantea sobre la teoría de **IHERING** en base a la problemática del error y en la invalidez del contrato. Al final está vinculado con la expectativa de validez del contrato, que implica ser colocado patrimonialmente como si el contrato hubiese desplegado su efecto principal que es el cumplimiento.
- **Interés negativo:** Es la dimensión inversa. Ante un contrato nulo, se pretende ser indemnizado y el punto para determinar acá es respecto de qué será indemnizado. En este caso se responderán no solo por las pérdidas sufridas, por ejemplo, los gastos de celebración del contrato, sino que también las ganancias dejadas de obtener por la no realización del negocio.

¿Existe alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico que permita acoger alguna de estas dos posiciones? R: en concreto la doctrina ha interpretado que el artículo 100 del Código de Comercio que dispone que: “La retractación tempestiva impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiere hecho, y **los daños y perjuicios que hubiere sufrido**. Sin embargo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar,

cumpliendo el contrato propuesto". Por lo tanto, se podría sostener que, en nuestro ordenamiento jurídico frente a un retiro injustificado de un proceso negociador, podríamos reclamar por concepto de indemnización la disminución patrimonial efectiva por la no realización de ese negocio (representar los gastos como daño emergente) y todo otro daño que esté vinculado a ese retiro injustificado, como el lucro cesante.

Hay una diferencia entre la tratativa de los tratos previos y el contrato de promesa. Esto último porque el contrato de promesa es precisamente un contrato que tiene por objeto la celebración de un contrato prometido, por lo que se diferenciaría totalmente de las tratativas preliminares.

¿La naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual? R: es extracontractual, ya que no existe un estatuto concreto de responsabilidad precontractual en nuestro ordenamiento **¿tiene alguna importancia la determinación de la naturaleza jurídica de la responsabilidad?** R: Si. Esto porque existen muchas diferencias entre ambos regímenes de responsabilidad. La regla general en materia contractual, es la presunción de culpa cuando existe incumplimiento y además la culpa está graduada. En la extracontractual no se presume la culpa de forma general, sino que hay ciertos supuestos en el Código Civil que se ocupa de la presunción de culpa, pero no es la regla general. Otra diferencia es el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria. En el caso de la responsabilidad civil contractual es de 5 años y en la extracontractual es de 4 años y si estamos en responsabilidad contractual en materia mercantil es de 4 años.

19 abril de 2018

4.5._ Tópicos doctrinarios sobre la diferenciación de las tratativas preliminares y otras figuras.

Estamos a punto de terminar lo relacionado con la precontractualidad, todo este proceso previo al momento de la formación del consentimiento y del contrato. Hay algunos elementos que hemos analizado que es necesario internalizar. A continuación, analizaremos temas que no han sido totalmente resuelto por la doctrina o la jurisprudencia. Tenemos códigos (civil y comercial) que son la base de los contratos, pero del siglo XIX. Y salvo las normas de la contratación estandarizada, el resto de las normas en general son normas que están estructuradas en la base y en el contexto histórico muy distinto al que actualmente podemos observar.

Sin embargo, debemos buscar la forma en nuestro propio ordenamiento jurídico para resolver los problemas que se han presentado en esta unidad de todo ese proceso previo a la presentación y la formulación de la oferta –acto jurídico unilateral-, que una vez aceptada por el destinatario o aceptante, forma este vínculo jurídico entre las partes.

En los temas de la precontractualidad, hay tópicos que tratan los autores que están relacionados con la diferenciación de las tratativas preliminares y otras figuras:

a) Tratativas preliminares y el contrato de promesa

Hay una gran diferencia entre los tratos previos, las cartas de intención y la negociación del acuerdo que se contextualiza dentro del proceso negociador y el contrato de promesa. **El contrato de promesa es un contrato que está reconocido en nuestro derecho expresamente en el artículo 1554 del Código Civil.**

¿Qué efectos produce la celebración de un contrato? R: Derechos y obligaciones. **Las obligaciones son un vínculo jurídico y están reguladas en el libro IV artículos 1437 y siguientes.** En el libro IV se define el contrato o convención (art. 1438): *“es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”*. Por lo tanto, existen obligaciones de dar, hacer o no hacer.

El contrato de promesa engendra una obligación de hacer. El Contrato de promesa está regulado en el artículo 1554 en nuestro Código Civil y dispone:

Art. 1554. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes:

- 1ª. Que la promesa conste por escrito;
 - 2ª. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces;
 - 3ª. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;
 - 4ª. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
- Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente.

Es un contrato que engendra una obligación de hacer y para que produzca sus efectos deben concurrir los siguientes requisitos:

- **Debe constar por escrito:** y este constar por escrito puede ser instrumento público o privado. Si no está por escrito, no produce efecto alguno.
- **El contrato prometido no debe hacer de aquellos que las leyes declaren ineficaces:** el objeto del contrato de promesa, que está representado por la obligación de hacer, consiste en que nos pongamos de acuerdo en que vamos a celebrar un contrato (llamado contrato prometido). Pero ya hay un vínculo contractual, ya que, a diferencia del trato previo, el contrato es ejecutable y puedo hacer ejecutar la obligación de celebrar un contrato y si existe incumplimiento generará responsabilidad contractual. En cambio, en los tratos previos, cuando no existe ningún vínculo, la responsabilidad es extracontractual. Esta **es una diferencia importantísima.**
- **Debe contener un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato prometido**
- **En la promesa deben especificarse de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.**

Esto es muy importante y cuidado con confundir dentro del proceso negociador, los actos preparatorios no vinculantes y el contrato de promesa.

b) Tratativas preliminares y el contrato de opción

El contrato de opción no está reconocido expresamente en nuestro derecho, pero en virtud de la autonomía de la voluntad, podríamos celebrar este tipo de contrato y cualquier otro (solo limitado por el orden público, las buenas costumbres, etc.). Es un contrato innominado en cuanto a la denominación genérica de opción. *Es una promesa, que contiene la facultad de una de las partes de optar unilateralmente por la celebración del contrato prometido.* Finalmente es “si yo quiero”.

En la **Ley de sociedades anónimas** podemos señalar pactos de accionistas y la celebración de contratos de opción preferente. Esto quiere decir que cuando se quiera vender mi acción, otro tendrá

el derecho preferente de comprar esa acción, pero puede no ejercer ese derecho. Si no lo ejerce, podrá vender mi acción a un tercero. Unilateralmente una de las partes puede concurrir a la celebración de esta especie de contrato prometido.

c) **Incluso algunos refieren dentro de esta precontractualidad el contrato de corretaje.**

El contrato de corretaje efectivamente se encuentra dentro de la etapa precontractual, pero también está dentro de la contractual. **El contrato de corretaje es un contrato que tiene por objeto mediar –mediación asalariada– es decir, lograr que dos partes se acerquen para la celebración de algún negocio específico o particular.** El contrato de corretaje provoca una especie de relación tripartita. Un corredor media a dos personas para que celebren un negocio jurídico y al mismo tiempo existe un contrato de corretaje entre las partes y el mediador. (Entonces hay relación contractual entre: parte-mediador, parte-mediador y parte-parte). Es una obligación de medios y no de resultados.

¿Participó ese contrato de corretaje en la precontractualidad? R: Obvio, evidentemente. Pero hay ciertos contratos, como los de seguros o los que celebran los asesores previsionales en materia de pensiones, en que el vínculo contractual que tiene el mediador con las partes en materia precontractual se mantiene durante la vigencia de ese contrato celebrado entre las partes. Esto porque estas personas –mediadores– tienen la obligación de asegurar (como una de las obligaciones del contrato de corretaje) a tal persona, el cumplimiento o la ejecución del contrato.

Entonces, cuando se enuncia que el corretaje está dentro de la precontractualidad es acertado, pero no es un acto preparatorio, sino que es un contrato que participa y que tiene una función dentro del proceso precontractual.

Por eso, hay muchos elementos que hay que precisar y determinar en estos procesos de negociación. Podemos vernos enfrentados a procesos complejos donde se verán cartas de intención, documentos, etc. Podríamos encontrarnos con un contrato de promesa, habría que determinar los requisitos. Por otro lado, también habría que atender si efectivamente se declaró unilateralmente una oferta.

Entonces, tenemos: **Periodo de negociación de tratos previos y dentro de este periodo tenemos: (i) los deberes de información, (ii) la ruptura injustificada del periodo de negociación (que podría generar responsabilidad extracontractual si se dan los supuestos ya analizados) y (iii) luego la oferta y la aceptación para finalmente celebrar el contrato.**

La problemática de los deberes de información, ya señalamos que tenemos un sistema (a diferencia del sistema del common law) de contrato informado –como lo dice la doctrina italiana–. Es tanta la exigencia de la buena fé, que tenemos que tomar todo aquello que permita a la otra parte tener claridad absoluta del objeto del contrato.

Hay deberes de información que están explicitados en nuestro ordenamiento. En materia de derechos al consumidor están explicitados, no es la buena fé la que me impulsa a informar en este caso, sino la ley.

4.6. Caso de Cicerón c:

“Un hombre bueno lleva desde Alejandría a Rodas una carga de trigo en un tiempo en que los Rodios sufren de escasez y hambre por falta de alimento. Sabiendo el que había levantado anclas del puerto Alejandría otros mercaderes y viendo que las naves cargadas de trigo iban camino a Rodas. ¿Debe decir a los Rodios o callarse para vender su mercadería más cara? Este es un relato de Cicerón y es uno de los primeros ejemplos que la doctrina ha levantado sobre la problemática de los deberes de información.

Cicerón responde: Aquel comerciante de trigo no debió ocultar nada a los rodios, porque el ocultar no consiste en callar cualquier cosa sino, el querer en un provecho que lo que tú sabes, lo ignoren otras personas a quienes sería útil el saberlo. ¿Quién no advierte la índole de este ocultar y de quienes es propia? No lo es ciertamente de un hombre sencillo, bueno y justo, sino de un hombre taimado, astuto, falaz, malicioso, sagaz, bellaco. ¿No es inútil el hacerse merecedor de tantos y otros muchos nombres infamantes?

En esto, no hay una respuesta absoluta ni una receta. Hay casos en que la ley determina el contenido del deber y al hacerlo fija el límite. El problema es cuando la ley no explicita el deber y es la buena fé objetiva la que establece el límite. El juez caso a caso deberá apreciar prudencialmente si se cumplió o no este requisito.

Lo interesante de este análisis es que lo toma Santo Tomás y además Pothier. (Leer en PPT).

IV.

EL CONTRATO EN MASA Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. CONCEPTO Y GENERALIDADES

Este es un fenómeno vinculado al problema de la mercantilidad. Cuando definimos el derecho comercial sobre la base de nuestro Código de Comercio indicamos la concepción objetiva y explicamos como la doctrina ha ido progresando e incorporando una serie de tesis para entregar un nuevo concepto de derecho comercial. Uno de los elementos o fenómenos que la doctrina ha observado para elaborar un nuevo concepto del derecho comercial sobre la base de la empresa son los actos en masa y dentro de los actos en masa encontramos los contratos en masa, que es muy representativo del tráfico actual.

El origen económico del contrato en masa lo podemos identificar a partir de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, cuando ciertas actividades o industrias tienden a pre elaborar condiciones generales y a estandarizarlas, con el fin de hacer más eficiente el desarrollo de su negocio. Muy tipo de esta estandarización son las actividades de la banca y los seguros. Estos últimos son los que tendrán mayor relevancia y se desarrollarán de mejor manera y de forma exponencial en el fenómeno de la contratación en masa o estandarizada, pero la problemática del contrato en masa, que está representada en las condiciones generales de la contratación, se vincula con el principio de la autonomía privada de la libertad y la libertad contractual en consecuencia. El contrato en masa que podemos identificar con las condiciones generales de la contratación, son **contratos pre elaborados o predispuestos por una de las partes (el empresario en concreto)**. Este tipo de contratación está vinculada además a una especial categoría de contrato –atribuida a un jurista francés– que es el **contrato de adhesión** y que, en nuestra doctrina, CLARO SOLAR la identifica como el “la toma o la deja”

La pregunta que nos formularemos es **¿qué problemas podemos levantar en esta terminología de la contratación en masa o estandarizada, representada en las condiciones generales de contratación?:** Problemas en el proceso negociador, hay desigualdad de las partes, asimetría de la información (lo que significa desigualdad). **La asimetría es un problema geométrico y de desigualdad y esto desde el punto de vista del derecho de contratos, puede provocar un problema desde el punto de justicia contractual o justicia conmutativa.** Esta situación de igualdad de prestaciones e igualdad de posiciones es lo que se trastoca con la asimetría y esto se produce claramente en el fenómeno de la contratación en masa, que está representada en el uso de condiciones generales de la contratación.

¿Cómo se resuelve en el fenómeno de la contratación en masa este problema? ¿Qué herramientas tiene el ordenamiento para responder a este problema? R: **el deber de información y las cláusulas abusivas.** Uno de los instrumentos que el legislador entrega para resolver la problemática de la simetría, son los deberes de información. Entonces, cuando celebremos un contrato que está integrado con condiciones generales de contratación, este proceso debe estar integrado con una etapa previa de información para que se consienta de forma informada y libre. Esto último, aunque solamente haya

sido puesto en la posición de informarse, ya que en el problema de la asimetría de la información existe un problema denominado **racionalidad imperfecta**. Este concepto levanta la interrogante siguiente: el problema no está en cuanto informo sino en **cómo lo informo**. Si se informa en exceso, paradójicamente puede producir un problema de desinformación, ya que con tanta información ni siquiera dan ganas de informarse.

Entonces, la doctrina ha pretendido resolver este problema pretendiendo que la persona quede **en la posición de informarse**.

Otro de los temas importantes de las condiciones generales de la contratación es preguntarse si nosotros podemos sostener que las condiciones generales del contrato puedan ser fuente de derecho objetivo. Existió un periodo breve en la doctrina alemana que sostuvo que las condiciones generales de la contratación, al estar vinculadas a las cláusulas de estilo y por lo tanto a los usos mercantiles, podrían ser calificadas como fuentes objetivas del derecho y eso hoy en día, es una corriente doctrinal que decae. No hay ningún autor que argumente que una condición general de la contratación pueda ser considerada como fuente de derecho objetivo, ya que no es una ley, por ejemplo.

(Esto suena a pregunta de prueba): Las condiciones generales de la contratación están directamente vinculadas al acto de consumo y al contrato de adhesión y están reconocidas normativamente en nuestro derecho. El artículo 1º N°6 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor dispone:

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

6.- Contrato de adhesión: aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.

IMPORTANTE: Nuestro ordenamiento reconoce el contrato propuesto unilateralmente por una de las partes expresamente en el N°6 del artículo primero de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

26 de abril de 2018

2. CONTROL DE CONTENIDO Y DE TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Ambos mecanismos son controles muy importantes en los contratos predispuestos. La ley se ha ocupado de considerar este tipo de control. **Las condiciones generales se integran al contrato a una condición particular**. Una vez que se integran –ambas-, estamos en presencia de un contrato. La condición general es un contrato predispuesto, que es redactado por una de las partes (proveedor) y la condición particular que se refiere a los elementos específicos del contrato (precio, individualización de las partes, etc.).

La ley se ocupa del control de contenido con una finalidad fundamental: **proteger al consumidor**. Y se ocupa del control de transparencia también para una protección. **El control de contenido** en el sentido de protección busca garantizar ciertos derechos básicos o mínimos en favor del consumidor. En cambio, **el control de transparencia** busca asegurar la comprensión del contrato.

Dentro del control de contenido, existe un control de contenido **por inclusión y otro control de contenido por exclusión**:

- El control de contenido por inclusión quiere decir que el legislador se ha preocupado de garantizar o asegurar ciertos contenidos mínimo del contrato o ciertos derechos que deben contenerse en todo contrato entre un proveedor y un consumidor, esto está vinculado a los deberes de información.
- El control de contenido por exclusión son ciertas herramientas que contempla el legislador para excluir del contrato ciertas cláusulas que la ley ha considerado como abusivas y vulneran los derechos del consumidor. El control de contenido por exclusión está reconocido en la Ley Chilena en el artículo 16 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

Luego **tenemos el control de transparencia**, que la doctrina lo ha llamado un control formal del contrato y ese control de transparencia está reconocido por el legislador en los artículos 1 N°3 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y 17 a 17 L de la misma ley.

Veremos la teoría general de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y el temario de lo que se analizará será:

- ◆ **Estatuto normativo del consumidor**
- ◆ **Problemática de aplicación de la Ley de Protección de Derechos del Consumidor.**
- ◆ **Problemática vinculada a 3 criterios que nos permiten determinar el ámbito de aplicación:**
La doctrina ha levantado ciertos criterios para resolver el problema: un **criterio subjetivo** (apunta a determinar quién es proveedor y quien consumidor, esto estaría zanjado en el artículo 1 y 2 de la Ley de Protección de los Derechos de Consumidor), **un criterio objetivo** (determinación del acto, aquí hay muchos problemas y distinciones doctrinales fundamentalmente por la aceptación o no de la derogación de la teoría del acto mixto. Hay algunos autores que estiman que a partir de la modificación de la ley 19.555 el legislador habría derogado o desplazado la teoría del acto mixto –acto comercial para una de las partes y civil para la otra-) y **uno de exclusión respecto del ámbito objetivo.**

2 de mayo de 2018

3. ¿CÓMO SE CONFORMA EL CONTENIDO DE UN CONTRATO O SE INTEGRA UN CONTRATO CON ESTAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN?

R: **Por regla general se determina por la voluntad de las partes en virtud de la autonomía de la voluntad.** Luego, dependiendo del supuesto de si hay situaciones en las que el legislador estime que hay una asimetría o desventaja, se debe precisar ciertos contenidos que **deben** estar dentro del contrato o que deben sacarse o excluirse de ese contrato. Aquí está el control de inclusión y exclusión. En este espacio intermedio, debe haber elementos que deben estar en todo contrato (voluntad exenta de vicios, causa, objeto, etc.).

Para determinar el contenido contractual entonces:

- (i) la voluntad de las partes y lo que quisieron contratar.
- (ii) Luego si estoy en una relación de consumo, existen derechos que el legislador considera que deben encontrarse (control de inclusión), y no puede renunciarse. Incluso puede haber pactos que el legislador excluye a través del control de exclusión, por lo que se limita la autonomía de la voluntad.
- (iii) Las cláusulas generales se integran al contrato cuando se aceptan estas condiciones generales de contratación. Las condiciones generales de contratación son un formulario lleno de cláusulas, no un contrato. Estas condiciones se van integrando con las cláusulas particulares. Las condiciones se integran cuando existe una oferta y una aceptación.

Por esto, en las condiciones generales de contratación existe un control de contenido, ya que existen contratos de adhesión y una problemática con los consumidores, por lo que el legislador se encarga de que ciertos derechos que se hacen efectivos al integrar la relación jurídica y son abusivos, se excluyan de esta relación.

Artículo 16 de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor: Se refiere a las cláusulas abusivas.

Artículo 16.- No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

b) Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica;

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;

(Este es un extracto, el artículo es más largo. Solo mencioné lo que el profesor mencionó)

9 de mayo de 2018

V. LEGISLACIÓN DE DERECHOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1. GENERALIDADES Y FUENTES NORMATIVAS

Estatuto normativo histórico de protección al consumidor (primeras referencias):

- i. Ley Sherman Anti-Trust o anti-monopolio (1890-Estados Unidos)
- ii. Ley alemana de Préstamos (1894)
- iii. Ley de Contratos de Seguro francesa (1930)
- iv. Código Civil italiano (1942), su importancia radica en ser el primer texto normativo a nivel de Código en reconocer el principio “**pro-consumidor**”.

Estatuto normativo actual de protección al consumidor:

- **La constitución política de la república (CPR):** Hoy en día estamos en un contexto de constitucionalización del derecho privado, por lo que se encuentran fundamentos permanentemente en la carta fundamental respecto de problemáticas propias de derecho privado (ej. Principio de subsidiariedad en relación con la libre iniciativa económica). Hay constituciones, como la civil española o argentina, que se han preocupado de consagrar al consumidor como una parte débil. El derecho de la problemática de los consumidores está contenido en rango constitucional porque se inserta en la problemática de derechos fundamentales. El consumidor ha ido adquiriendo relevancia en normas supra legales, como lo muestran las normas de la ONU y UNCITRAL.
- **Ley 19.496 o LPDC:** vigente desde 1984 en Chile.
- **Ley de Estatuto Pymes:** Su artículo 9 permite considerar una Pyme como consumidor
- **Diversos Decretos Supremos que contienen reglamentos relativos a la protección de los consumidores.**

No obstante tener una LDPC en la legislación chilena, Hay **dispersión normativa** en cuanto a la protección de los derechos del consumidor. Hay una serie de normas o contratos dispersos en el ordenamiento que puede provocar incerteza en cuanto a la norma aplicable, es decir, si en ciertos supuestos se aplica la LDPC o no.

Por ejemplo, en ciertos contratos como los bancarios o de seguros –aunque se discute- en cuanto a qué norma primaría, respecto si prima la LDPC o normas del Código de Comercio respecto del Contrato de Seguro. En este contrato, un volumen importante de la actividad que desarrollan las industrias de seguros, es estandarizada o de adhesión. El año 2013, una reforma modificó la revocación del Contratos de Seguro, y el elemento central que guió la reforma fue incorporar normas para proteger a la parte más débil: el consumidor en los servicios de seguros o asegurado.

El problema aquí es que si nosotros aplicamos el criterio de ley especial-ley general, tengo normas contenidas en la LDPC y otras en el Código de Comercio, **¿qué norma prima?**

Vimos nosotros que los legisladores confeccionan normas en base a principios, uno de ellos es el de Orden Público de Protección. En relación a esto, Georges RIPERT señala que la mayoría de las normas contenidas en los códigos civiles decimonónicos que establecían criterios de protección a favor de incapaces quedaron superadas, porque hay supuestos en las relaciones contractuales en que existe una problemática de asimetría evidente entre una parte y la otra.

Se desarrolla, por tanto, este Orden Público de Protección como un principio contenido en diversas normas del ordenamiento, y que tiene por objeto entregar protección a esta parte en desventaja, tal como anteriormente la tenía el incapaz.

Hoy en día tenemos un **problema**: Si tengo una norma en el Código de Comercio, en temas de seguro, que es posterior a la LPDC, se revisa el mensaje de esa moción parlamentaria y lo que inspira a cada numeral es el principio de Orden Público de Protección, es porque aquella busca cumplir la misma función que la LPDC, pese a ser esta última especial, el fin de la norma en muchos casos podría no cumplirse por este criterio de la especialidad y generalidad, que impide la aplicación frente a la LDPC (incluso hay normas en el Código de Comercio que son incluso más protectoras que la LPDC). Hay autores (BARRIENTOS) sostiene que, en esos casos, los contratantes que están en la posición de debilidad tendrían la posibilidad de optar entre una u otra.

Hoy en día, hay diversas legislaciones como la argentina, que tiene un **código unificado** (2015), en que existe un solo derecho de obligaciones. Éste contiene normas que reconocen y regulan materias de asimetría, por lo que señala diversas reglas que buscan proteger al contratante débil. Sin embargo, existen otras leyes anteriores a este código a las que éste les “concede vigencia”. Claramente hay cierta contradicción entre estas normas, entonces ¿cuál se aplica?

Opinión del Profesor: En estos casos (contrato de seguros), en virtud del principio del OPP primarían las normas del Código de Comercio respecto de la LDPC, cuando se está en una relación de consumo. Pues, si tienen el mismo fin común y se complementan, no tiene sentido que se discuta qué norma tiene prevalencia, pues el mismo Código de Comercio reconoce al consumidor al regular el contrato de seguros, tal como lo hace la LDPC, y su principio inspirador es el mismo.

Hoy en día existe este gran problema respecto de la dispersión normativa, la que debe ser despejada para ir determinando en qué casos se puede aplicar una u otra norma. La ONU, el año 1985, hizo reconocimiento expreso de los consumidores respecto a su desequilibrio en capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación, teniendo en cuenta que los consumidores debe tener acceso a productos no peligrosos, debiendo promoverse el desarrollo económico y social justo.

Por esta razón, algunas cartas fundamentales reconocen al consumidor en el contexto de los derechos fundamentales. Si revisamos la historia de la ley (1949) podemos encontrar una cierta coincidencia con los objetivos que expresa la ONU, al considerar que es responsabilidad del Estado el cautelar los intereses de los grupos sociales no organizados, como son los consumidores.

¿Qué justifica, entonces, incorporar normas tutelares respecto a la protección de consumidores?

Fundamentalmente la asimetría, esto provoca un desequilibrio entre partes.

Los iusnaturalistas siempre entendieron que los contratantes estaban en una posición de igualdad, pero CASTRO dice que esto es muy utópico, nunca ha existido igualdad absoluta. Hay casos en que existiendo una desigualdad considerable que afecte la justicia contractual, **se incorpora el**

mecanismo de protección, para que una parte no se vea extremadamente mejorada y otra extremadamente perjudicada. Esto tiene su fundamento en el Orden Público de Protección, aunque nunca ha existido claridad respecto de un concepto de orden público, pero sí podemos entender que está conformado por todos aquellos principios y normas que buscan regular este desequilibrio provocado por esta asimetría, y que trastoca la justicia contractual.

Estos cuatro elementos limitan o restringen el principio de la autonomía de la voluntad. En este principio podemos deducir algunos elementos: podemos contratar cuando quiero, con quien quiero y como quiero. Hay casos en que el orden público restringe:

a) **contrato “cuando quiero”**, donde el legislador en esa *prima facie* de la autonomía de la voluntad, nos dice “oye, yo te puedo obligar a contratar” como en el caso de los seguros de accidentes personales (de autos) o los fondos de pensiones por contrato de trabajo, en que me veo obligado a contratar uno.

b) **contrato “con quien quiero”**, por ejemplo, en el caso de que cuando contratamos una Isapre o Banco o Empresas de Seguro, debemos contratar con una de estas instituciones. Existen ciertas exigencias de la ley, respecto del desarrollo de giros concretos, lo que nos obliga a contratar con ciertas instituciones.

Esto se relaciona con las funciones sociales del contrato, por ejemplo, si me compro un auto estoy obligado a contratar un seguro, pues si choco y daño a alguien el Estado no está dispuesto a hacerse cargo.

c) **contrato “como quiero”**, ya que en materia de protección del consumidor hay control de contenido del contrato.

Recordatorio: En nuestro ordenamiento jurídico están reconocidas las condiciones generales de la contratación, en el Código de Comercio Art. 1 N°6. Existían dos tipos de control de Transparencia y Contenido. En este último, hay uno por inclusión y exclusión.

- i. En el control de inclusión, hay ciertos contenidos o derechos esenciales establecidos en la ley, que son controlados por el legislador y siempre deben estar incluidos en la relación de consumo, sin importar si están explícitos o no. Son las condiciones mínimas que debe tener todo contrato.
- ii. En el control de exclusión, hay ciertas cláusulas abusivas que no pueden incluirse y se tendrán por no escritas.

El orden público de protección, lo que hace es limitar el principio de la autonomía de la voluntad y libertad contractual. Sobre todo, en la relación de consumo, muy especialmente el contenido del contrato.

Para poder determinar cuándo hay una relación de consumo, que justifica la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, la doctrina propone una distinción entre los siguientes criterios copulativos:

- Criterio subjetivo: calidad de consumidor (art 1 n° 1) y proveedor (art. 1 n°2)
+

-
- Criterio objetivo: actos de consumo (art. 2 y 2bis)
 - =
 - Criterio de exclusión: (art. 2 bis.)

Se obtiene así la relación de consumo.

10 de mayo de 2018

Paréntesis del Profesor: la habitualidad está relacionada a la profesionalidad más que con la reiteración de una conducta (art. 7: habitualidad vs. art. 8: accidentalidad)

Corrección de orden de prelación de fuentes:

- ✓ Constitución Política de la República
- ✓ Leyes Mercantiles (Código de Comercio y leyes especiales)
- ✓ Código Civil
- ✓ Costumbre
- ✓ Tratados Internacionales: si están ratificados se consideran como leyes especiales, pero si no son vinculantes quedan al final como costumbre (ej. Leyes UNCITRAL, que son recomendaciones no vinculantes).

Pregunta de clase: Si una ley especial dice algo distinto al Código de Comercio, **¿prevalece ésta de todas formas?** JEQUIER dice que prevalece la **ley especial**, que se aplica con anterioridad al Código de Comercio. Sin embargo, hoy esto se discute pues se han incorporado regulaciones al Código de Comercio en el mismo sentido que la LDPC, en razón del orden público de protección, por lo que algunos dicen que se podría aplicar con anterioridad el Código de Comercio, éste un problema no resuelto en la doctrina. Algunos dicen que el consumidor podría **optar** entre el Código de Comercio y la ley especial, pero la doctrina mayoritaria, sin embargo, sigue aplicando el principio de especialidad versus generalidad. Este problema no está zanjado.

Pregunta de clase: ¿Qué plantean la teoría de los actos en masa y la teoría de la empresa? La crítica que hace la **teoría de los actos en masa** al artículo 3, respecto al principio objetivo del acto de comercio, es que hay actos que quedan fuera de éste pero que son parte del tráfico mercantil y se realizan de manera estandarizada (ej: a través del e-commerce). La **teoría de la empresa** se refiere a la figura del comerciante, diciendo que ésta es insuficiente para explicar la problemática del derecho mercantil.

Continuación de la clase: Derechos del consumidor

El legislador chileno regula la problemática del consumo en la ley 19496, junto con distintas modificaciones que se han ido introduciendo en el transcurso del tiempo. En este sentido, La LDPC generó un quiebre en la regulación del tráfico mercantil, fundamentalmente porque la tendencia de los tribunales hasta ese entonces era resolver estas problemáticas por medio del cruce entre el art. 3 con las normas del CC, pues no existían normas de protección. La pregunta más relevante que se ha ido asentando y que se responde constantemente es ¿qué es una relación de consumo? Esto es esencial, pues la **relación de consumo** me permite determinar si aplico la LDPC o no.

¿Cómo se determina la relación de consumo?: ejercitando la identificación de ciertos criterios.

a) **Subjetivo:**

Permite determinar quiénes son consumidor y proveedor. Esto se encuentra en los Art. 1 n° 1 y n°2.

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1.- Consumidores o usuarios: las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores.

2.- Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.

No se considerará proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.

Del art. 1 n° 1 podemos desprender ciertos requisitos vinculados con el concepto de consumidor y esos son fundamentalmente los siguientes:

- a. **una noción de destinatario final**
- b. **un acto jurídico oneroso**

Frente a la misma definición de destinatario final, tenemos la problemática del **consumidor jurídico y el consumidor material**. En este sentido, La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió hace muchos años un caso de una señora que fue y compró un yogurt al supermercado y uno de los hijos se intoxicó. Ahí hay un consumidor jurídico y un consumidor material, ¿protege la ley a esa persona?

Pero hay otra problemática a considerar, respecto del **empresario y el consumidor**, ¿existe la posibilidad de que en ciertos casos empresarios, proveedores o comerciantes (sean o no personas jurídicas) puedan ser considerados consumidores? Ese es otro punto relevante que contiene nuestro ordenamiento jurídico, relacionado con el Estatuto Pyme.

Hay dos criterios para determinar la calidad de destinatario final:

- a. **criterio positivo:** La persona que ejecuta el acto que la ley considera calificado como acto de consumo. La doctrina chilena admite que este es el criterio recogido en el artículo 1 de la LDPC.
- b. **criterio negativo:** La persona que no actúa con un fin relacionado a una actividad profesional. Este es propio del sistema europeo.

Otro problema relacionado con la calidad de consumidor del individuo, y en que la ley es poco clara, es el **acto oneroso**. Cuando el art. 1 se refiere al acto jurídico oneroso, se entiende que proviene de

una relación bilateral. Hay un error de la ley ahí, porque si entro a un supermercado y me caigo ¿la LDPC me protege? **Sí**. Uno de los derechos del consumidor más importantes es la seguridad en el consumo.

Así, se genera un vínculo por responsabilidad extracontractual entre el consumidor y el proveedor sin necesidad de que haya una relación contractual previa. La LDPC reconoce expresamente la relación extracontractual. Por tanto, hay un problema en la definición de consumidor como requisito para quedar amparado por la LDPC.

El profesor dice que la doctrina trata de justificar lo injustificable, porque la LDPC dice: "acto jurídico oneroso", y MOMBERG dice que el texto de la ley no exige una relación contractual, que va contra el propio espíritu de la ley dejar en desprotección al consumidor, por tanto, ha de extenderse al ámbito extracontractual. Entonces podemos ver que en muchos casos la ley es muy poco clara y la doctrina también.

- b) **Objetivo:** implica determinar qué acto puede calificarse como acto de consumo (art. 2 y 2 bis)
- c) **De exclusión:** criterios establecidos en la ley (art. 2 bis)

15 de mayo de 2018

2. APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Para aplicar la LPDC se necesita que exista una relación de consumo. El siguiente paso es determinar **cuándo estamos frente a una relación de consumo. Criterios de la doctrina:**

2.1. Criterio Subjetivo

a) **Consumidor.** 1 N° 1 de la LPDC:

"Consumidores o usuarios: Las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores".

No obstante, existe una discusión doctrinal y jurisprudencial respecto de los elementos que se contienen en la definición de consumidor:

- i. **Persona natural o jurídica:** respecto de las personas naturales no hay ningún problema (en legislación comparada se dice lo mismo). Pero respecto de las personas jurídicas se ha generado una discusión doctrinal, porque inicialmente, y antes de la modificación de la ley 20.416 (de PYMES), se entendía que solamente quedaban protegidas bajo el amparo de la LPDC las personas jurídicas sin fines de lucro, ya que las con fines de lucro más bien se confundían con la calidad de proveedor.

Sin embargo, la ley 20.416 sobre estatuto pyme, reenvía en el artículo 9 a personas jurídicas con fines de lucro a la LPDC. La problemática que se produce respecto de estas personas jurídicas pymes y que no está resuelta, es precisar y determinar en qué caso una pyme puede ser considerada como

destinatario final. Y esto lo dejaremos como una interrogante (se verá en análisis del destinatario final).

- ii. **La ejecución de un acto jurídico oneroso para adquirir, utilizar o disfrutar:** respecto de este, ya revisamos lo que expone la doctrina que parece confusa. Primero, la doctrina ha señalado y la jurisprudencia ha ido recogiendo, es que cualquier acto que sirvan de complemento de un acto jurídico oneroso, están amparados por la LPDC. ¿Y si no hay un acto jurídico oneroso, podría entenderse bajo algunos supuestos que si se aplique la LPDC? En general se distinguen dos casos muy claros, vinculados con los supuestos en que se aplica la LPDC:
 - a. Artículo 3 de la LPDC establece en la letra c): “El no ser discriminado arbitrariamente por proveedores de bienes y servicios”. Ej: restaurant no dejó entrar a jóvenes Down, por lo cual recibió sanción.
 - b. Artículo 3 de la LPDC establece en la letra e): cuando alguien entra como potencial consumidor y sufre un daño, está protegido por la LPDC. En estos casos, estamos frente a un supuesto generalmente de responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, cuando la ley se refiere al acto jurídico oneroso, debíamos sortear esa frase (que parece restrictiva) y a extenderlo a otros supuestos. Si se va a la teoría del acto jurídico. Mombert señala que debe hacerse una interpretación extensiva, pero no otorga ningún elemento real o fundamento jurídico sólido para sustentar aquello. Según el profesor es el fin de la norma es el que permite dicha interpretación.
- iii. **Destinatario final:** nuestro ordenamiento ha recogido este criterio positivo. Es consumidor quien adquiere disfruta o utiliza como un destinatario final. Esto a diferencia de los sistemas europeos que establecen que es consumidor quien no ejecuta una actividad profesional. En este punto es posible distinguir entre:
 - i. Consumidor jurídico: quien interviene en el contrato objeto de la relación de consumo.
 - ii. Consumidor material: quien de hecho consume o usa los bienes, o quien utiliza los servicios

Hoy la tendencia es señalar que en razón del cumplimiento del fin de la norma la **LPDC protege no solo al consumidor jurídico, sino que también al material**. La jurisprudencia ha dicho que: el acto jurídico que menciona el artículo 1º N° 1 es el factor de atribución que permite imputar a un proveedor determinado los efectos de este cuerpo legal, pero los afectados por esta relación de consumo pueden ser otros sujetos que no intervienen en el acto jurídico. Se da el ejemplo del miembro de una familia que adquiere un bien que disfruta toda la familia.

- Caso de las personas jurídicas.

Desde el artículo 1º N°1 “En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores” las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro no estarían protegidas por la LPDC. Sin embargo, en la ley 20.416 en el artículo 9 reenvía o le entrega la posibilidad a una **pyme** de quedar protegida por la LPDC. El problema es cómo podemos identificar si una pyme es o no un destinatario final.

La **jurisprudencia** y la doctrina han establecido que debe entenderse que las pymes podrán considerarse destinatarios finales, cuando los bienes que adquieran no estén destinados al desarrollo de su giro.

Ejemplo: don Ariel tiene una empresa de delivery con 4 trabajadores, pongámonos en dos supuestos: 1) Ariel compra siempre almuerzos a sus trabajadores y un día ellos se intoxican. 2) La misma pyme decide cambiar las motos de los trabajadores por bicicletas, para el desarrollo de sus actividades, las bicicletas salen con defectos. ¿Se aplica LPDC en ambos casos en amparo de la PYME? Respuesta: En el caso 1 la PYME se ve amparada por la LPDC y en el segundo caso no. En el primero se satisface una mera necesidad laboral, en cambio en el segundo se han adquirido bienes para el desarrollo del giro de la empresa.

Desde la **historia de la ley 20.416**. “La legislación de la protección a los consumidores, ha reconocido que quienes adquieren o disfrutan como destinatarios finales bienes o servicios enfrentan severas asimetrías que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Esto se explica por los costos que enfrentan en la resolución de controversias, por la falta de acceso a la información sobre los productos, o porque carecen de las competencias adecuadas para un correcto conocimiento del contrato que están celebrando. El sistema de protección a los consumidores busca atender en este sentido aquellas brechas entre los contratantes del mercado estableciendo estándares mínimos, prohibiendo la inclusión de cláusulas abusivas, y sancionando las infracciones que afecten el interés de los consumidores. Esta normativa, sin embargo, solo se aplica a los consumidores finales y **sin considerar que las empresas más pequeñas en muchas ocasiones compran bienes y/o contratan servicios siendo afectadas por el mismo tipo de asimetrías antes mencionadas**”.

En conclusión. En el caso de las pymes hay que distinguir si el bien adquirido es para uso profesional o del giro o no. Cuando no lo es, podría ser considerado como consumidor. Cuando lo es, debe considerársele proveedor.

b) **Proveedor.** 1 N° 2 de la LPDC.

“Las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.

No se considerará proveedores a las personas que posean un título profesional y ejerzan su actividad en forma independiente.”

Son proveedores de acuerdo a esta definición:

- i. **Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado**
- ii. **Que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción o comercialización de bienes o servicios.**

Hay puntos de conflicto de la ley que están relacionados fundamentalmente con la cadena productiva y las problemáticas de infracciones civiles que se pueden provocar en un proceso productivo.

- I. **1er conflicto:** el proveedor directo y el mediato. La ley distingue entre el proveedor que interviene directamente en la relación con el consumidor y el proveedor mediato, que es parte de la cadena productiva pero no se relaciona directamente con el consumidor.

Art'. 47 LPDC: Declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente de acuerdo a las normas especiales a que se refiere el artículo 44, la peligrosidad de un producto o servicio, o su toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los **daños o perjuicios** que de su consumo provengan serán de cargo, **solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, en su caso.**

Por tanto, en materia de proveedores, principalmente en temas de responsabilidad por productos defectuosos, el legislador establece un criterio extensivo en el concepto de proveedor. No sería proveedor solamente el directo, sino también aquel que interviene en la cadena de producción (proveedor mediato). Se extiende el concepto de proveedor no solamente respecto de la persona que celebra acto o contratos con el consumidor.

- II. **2º conflicto:** es el relacionado con la habitualidad. La doctrina ha señalado que no debe identificarse con la periodicidad, sino con la profesionalidad.

Existe un criterio de exclusión en la LPDC, presente tanto en la definición de consumidor como en la de proveedor. En la definición del consumidor el art. 1 N° 1 inciso final señala: En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores ". Y respecto del concepto del proveedor –y en relación con el concepto de habitualidad y profesionalidad–, el art. 1 N° 2 inciso 2 expresa: "no se considerará proveedor a aquellas personas que tengan un título profesional y ejercen su profesión de forma independiente".

Por lo tanto, para que opere la exclusión en los proveedores no basta el título profesional (ej: ser abogado), debe tratarse de una profesión ejercida en forma independiente (no trabajar para una empresa). Si la persona ejecuta la profesión a través de una forma societaria, como empresa, será considerada como proveedor.

a. **Criterio objetivo: el acto**

Ámbito de aplicación de la ley en el acto de consumo. Art 2 LPDC:

"Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: a) Los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor. [b),... c)... listado sigue]"

La ley 19.555 modificó la letra a) del artículo 2. Muchos civilistas dicen que con esta modificación habría quedado eliminada la teoría del acto mixto. Argumentan que al haberse eliminado la expresión "solo" de la letra a) del artículo 2, se habría derogado el acto mixto.

MOMBERT dice que esta norma hace referencia a los actos mixtos, en que un mismo acto puede ser mercantil para una de las partes (en este caso el proveedor) y civil para la otra (consumidor). Señala que el carácter mixto del acto era, antes de la reforma del año 2004, uno de los requisitos generales para la aplicación de la LPDC. El artículo señalaba:

“Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que de conformidad a lo preceptuado en el código de comercio u otras disposiciones legales tengan el carácter de **mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor**”

Según la doctrina y jurisprudencia la expresión **“sólo”** indicaba el sentido claro de excluir del ámbito de aplicación de la ley todo acto que no pueda ser calificado como acto mixto. De acuerdo a lo que señala MOMBERT, la nueva redacción ya no está redactada en términos excluyentes, sino que se limita a enumerar actos y contratos a los cuales es aplicable la LPDC. Del análisis comparativo de ambos textos puede deducirse que la circunstancia de que el acto objeto de la relación de consumo tenga el carácter mixto ha dejado de ser requisito general, y solo es uno más de los casos que la ley aplica de manera que esta puede aplicarse perfectamente a actos que no tengan el carácter de mixtos

En conclusión, según cierta doctrina: habría derogación de la teoría del acto mixto:

- ✓ **antigua redacción:** era un requisito general que se tratase de actos mixtos (“solo” a. mixtos)
- ✓ **nueva redacción:** la ley se puede aplicar a actos que no sean mixtos, los actos mixtos son solo una letra (a) de todo el listado de actos del artículo.

(*) **precisión:** por derogación no quiere decirse que la teoría esté derogada para todos los efectos en todo ámbito del derecho, sino que en materia de protección de los derechos del consumidor ha dejado de ser un requisito general para la aplicación de la LPDC.

16 de mayo de 2018

Dijimos que había tres criterios para determinar la aplicación de los derechos del consumidor. El subjetivo se refería a los instrumentos que nos entrega el ordenamiento jurídico, en particular la LPDC para identificar quién es consumidor, además de identificar quién es proveedor. La mejor forma para comprender es el artículo 1 N° 1 y 2 de la LPDC.

El criterio objetivo está representado **por el acto de consumo**. En este hay ciertos problemas porque las dos normas que nos permiten identificar el acto de consumo son el Art 2 y el Art 2 bis de la LPDC y en el 2 hicimos un análisis histórico:

Antes de la modificación de la Ley 19.555 se entendía que el requisito general para aplicar la LPDC era la identificación del acto mixto, es decir, que identifica a una parte como comerciante y a la otra como no comerciante. Parte de la doctrina (extrema) señala que esta norma derogó el acto mixto, otra parte que no, que lo que habría hecho era eliminar el acto mixto como requisito general, pero que aún subsistiría en la LPDC al ver el Art 2 N° 1 (y es lo que el profesor cree). La problemática de la referencia expresa que existía respecto del acto mixto (y que el profesor cree que aún subsiste), es que el artículo 3 del coco es taxativo (de acuerdo a cierta doctrina) y aun no siendo taxativo aplicando la teoría de lo accesorio, finalmente no incluye muchos actos que en la teoría del derecho comercial pueden ser considerados como actos de comercio y evidentemente hay muchos actos que no están enumerados en el Art 2 de la LPDC. **Esto se hace aún más evidente en la creación de distintas formas jurídicas de contratación a través del comercio electrónico** (teniendo en cuenta que su desarrollo es exponencial).

La única salida sería interpretar extensivamente la LPDC y entender que al enfrentarse a un individuo posiblemente calificado consumidor o proveedor, estaremos frente a una relación de consumo

La ley, no obstante, en el artículo 2 incorporó más actos que pueden ser considerados como actos de consumo (letra b, c, d, e, f del artículo 2 de la LPDC), como si el legislador quisiera resolver el problema. Podemos claramente entender que tenemos un problema, especialmente respecto de aquellos actos que podrían no estar enumerados en este artículo. **(Aprenderse el Art 2).**

Artículo 2º.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley:

- a) Los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor;
- b) Los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas;
- c) Los actos o contratos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor o usuario el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo;
- d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto del Párrafo 4º del Título II; de los Párrafos 1º y 2º del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren.

No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación;

e) Los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la ley N° 19.472, y

f) Los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud, con exclusión de las prestaciones de salud; de las materias relativas a la calidad de éstas y su financiamiento a través de fondos o seguros de salud; de la acreditación y certificación de los prestadores, sean éstos públicos o privados, individuales o institucionales y, en general, de cualquiera otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales.

Luego, para poder concluir con este proceso de precisión o **determinación del acto como elemento determinante de la relación de consumo, nos encontramos con el artículo 2 bis**. Que establece a que actos no será aplicable la relación de consumo.

Artículo 2º bis. - No obstante, lo prescrito en el artículo anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo:

- a) En las materias que estas últimas no prevean;
- b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento, y
- c) En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación contraída por los proveedores, siempre que no existan procedimientos indemnizatorios en dichas leyes especiales.

Es un criterio de exclusión. En todos aquellos casos en que las actividades de fabricación, construcción, intervención en general que estén reguladas por leyes especiales, no se aplica la LPDC.

Volvemos al caso que puede ocurrir en el proceso de modificación de legislación bancaria. Si al legislador se le ocurre incorporar en el coco toda la regulación de la banca (como se hizo con los seguros), estamos frente a un problema en la estructura general del derecho, ya que entenderíamos que es una norma general y no una especial, lo cual es un error, ya que la norma especial que regula el control de seguros (refiriendo al caso de los seguros) está en el Coco, no en una ley especial. Y la relación de especialidad que se da acá es: Ley general: LPDC y ley especial: normas contenidas en el Coco. Y si el legislador sigue avanzando e incorpora toda la legislación bancaria en el coco se daría el mismo problema. Debiera entenderse que ley especial: LPDC, y ley general en el Coco³.

El legislador estaría reconociendo, no de manera expresa, que en algunos casos la LPDC es supletoria. Y teniendo en cuenta que, como la problemática del consumo se va insertando en gran manera (el tráfico en un porcentaje importante está relacionado a problemas de consumo), ya el legislador está reconociendo que la ley en ciertos casos es considerada ley general, no especial, pero no puede “ser considerada” ley general, o es ley especial o no es ley especial. Finalmente, su aplicación es supletoria en casos regulados por leyes especiales, lo cual se resuelve caso a caso.

Hay autores que, para resolver este problema, han señalado que la ley o la problemática del consumo, se ha generalizado de tal manera, que es parte del derecho común, por lo tanto, hay autores que sostienen que la LPDC sería ley general y no especial. Hay ordenamientos jurídicos que incorporaron en su CPR un artículo expreso y especial de protección de los derechos del consumidor. Entonces esta problemática de la generalidad y especialidad, se nos comienza a desmoronar (debido a la dispersión normativa), generando problemas que hay que resolver.

Pero se agrega en las letras a, b y c una contra excepción en el artículo 2 bis (al final). Señala en la letra a que “en las materias que estos últimos no prevean”, se vuelve a la regla del Art 2. La regla general es la LPDC, y luego las especiales.

Para entender leer:

- ✓ **Artículo 2**
- ✓ **Luego artículo 2 bis**, que establece el límite de las leyes especiales.
- ✓ **Luego el artículo 2 bis al final**, que establece que aun cuando se encuentren en leyes especiales, si no se resuelve ahí, se vuelve a la LPDC.

Enunciaremos los derechos de los consumidores (que hay que memorizar):

1. Libre elección de bienes y servicios
2. Derecho a información veraz y oportuna
3. No ser discriminado arbitrariamente
4. Seguridad en el consumo de bienes y servicios
5. Derecho a la reparación o a la indemnización

³ En el audio el profesor dice dos veces “ley especial”, de manera que deduzco que quiere decir que la ley especial sea la LPDC y no el COCO.

La ley 20.555 en materia de servicios financieros, extendió para todas las problemáticas de los servicios financieros, ciertos derechos en favor de los consumidores. **Están relacionados fundamentalmente (sale en el ppt) con toda la información necesaria que debe recibir un consumidor de un crédito para comprender de la manera más clara posible el servicio que está contratando con la entidad financiera.**

Por ejemplo: de si es de condiciones de pago, interés, cargo por administración o por contratación de seguros. La próxima clase se avanzará en uno de los derechos más importantes que la LPDC establece para los consumidores: la irrenunciabilidad de los derechos del art. 4. Un proveedor jamás puede en un formulario o condición general incorporar una renuncia de los derechos de los consumidores. Lo único que puede hacer, es mejorar las condiciones del consumidor respecto de las establecidas en la ley, pero no puede exigirle su renuncia.

17 de mayo de 2018

El eje central de la ley es la irrenunciabilidad anticipada de los derechos del consumidor

- ✓ **Los derechos de los consumidores quedan protegidos por el criterio de irrenunciabilidad del artículo 4 de la LPC / Imperatividad**

Artículo 4º.- Los derechos establecidos por la presente ley son irrenunciables anticipadamente por los consumidores.

Está mal redactada: cómo se va a renunciar un derecho si no lo tengo, ya que no se ha celebrado un contrato.
La irrenunciabilidad consiste fundamentalmente en la imposibilidad o el límite que impone la ley al proveedor que generalmente pre elabora o predispone las condiciones contractuales e materias de consumo, respecto de la elaboración del contenido del contrato. El proveedor como proponente del contrato no puede disminuir o aminorar los derechos que establece la LPDC, sino la cláusula es nula. El profesor ha denominado esto como Imperatividad del contenido normativo, una inmovilidad del contenido normativo. Si el legislador consagra un derecho en favor del consumidor, el proveedor no puede alterar ni una coma de ese derecho, ya que podrían estar disminuyéndose los derechos que el legislador consideró fundamentales para el consumidor.

Esta irrenunciabilidad o Imperatividad, la podemos calificar de unilateral. Ya que ¿quién es el destinatario? R: el proveedor. Es la voluntad del proveedor la que está limitada o restringida en virtud de estos criterios de imperatividad, ya que normalmente es el que predispone el contenido del contrato en las relaciones de consumo.

No obstante, esta Imperatividad es declinable por parte del consumidor en todos aquellos supuestos en los que se establecen mejores condiciones para el consumidor. Por ejemplo: la ley establece la posibilidad -en ciertos supuestos- de retractarse al consumidor y concede un plazo para ejercer ese derecho de retracto, sin embargo, hay algún proveedor que se le ocurre modificar el plazo:

- **Si lo extiende:** puede ser renunciado por el consumidor, ya que es una condición favorable o mejorada en relación a la establecida por el legislador.
- **Si lo acorta:** se está generando una condición desmejorada o peor que la que estableció el legislador, luego el consumidor no puede renunciar a este plazo y la cláusula es nula.

✓ Otro de los aspectos importantes en la regulación de los derechos del consumidor son los relacionados a la formación del consentimiento:

1. El silencio **jamás constituye manifestación de voluntad en las relaciones de consumo**. Si en un contrato de consumo se incluye una norma que le da valor al silencio circunstanciado, es nula. La regla general, es que el silencio no constituye manifestación de voluntad, en el derecho comercial existe el silencio circunstanciado y en materia del consumidor nunca tiene valor.

En una relación de consumo, el silencio **JAMÁS, NUNCA, NUNCA puede tener valor como manifestación de voluntad**⁴. Y si se establece una cláusula que estatuya lo contrario es NULA. Esto porque el artículo 3 letra a).

Artículo 3º.- Son derechos y deberes básicos del consumidor:

- a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo

El silencio no constituye aceptación. El problema que hay hoy en día nace del juicio **Sernac V/s Cencosud**, el cual es si podemos identificar en materia de consumidores la voluntad tácita con el silencio. La doctrina ha dado un paso bastante importante al respecto, porque si revisamos este fallo o vemos cómo se produjo la operativa de Cencosud: cuando le llegaba la cuenta, en la letra chica se contenían frases de modificaciones contractuales, de manera que cuando ellos pagaban (los clientes), se entendía como una aceptación tácita de aquellas modificaciones contractuales.

La corte Suprema, da a entender que en ese caso había una vulneración al Art. 3 a) de la LPDC. El SERNAC al respecto siempre sostuvo que el consentimiento del consumidor siempre debe ser **expreso y escrito**. La CS no fue tan lejos, pero al señalar que en este supuesto hay una vulneración al Artículo recién señalado, supone que en aquella manifestación -que en el derecho común se entendería como una manifestación tácita de voluntad- hay silencio, lo cual está absolutamente prohibido y excluido en materia de relaciones de consumo.

2. Otro de los aspectos que está relacionado con el proceso de formación del contrato y formación del consentimiento son **los deberes de información**.

En materia de consumo hay dos artículos fundamentales: el artículo 3 letra b) que establece la obligación de informar veraz y oportunamente de los bienes y servicios ofrecidos, su precio y condiciones generales de contratación.

- b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos

Es decir, debe recibir de forma clara y precisa, toda la información sobre el contenido del contrato. Dentro de este mismo artículo, la ley 20.555 extendió nuevos deberes de información (el deber de información del proveedor de entregar el valor del costo total de los créditos). El Art 3 establece un

⁴ En un caso que no sea una relación de consumo valdría: el silencio circunstanciado.

marco de contenido de aquella información. Nosotros debemos entender que, si bien se refiere a los derechos del consumidor, hay un deber correlativo del proveedor en favor del consumidor, por lo que concluimos que en el Art 3 se establecen deberes de información.

Luego, esta norma del artículo 3, debemos relacionarla con el artículo 17 b de la LPDC (también incorporado por la ley 20.555) que establece deberes completos de información que pesan en el proveedor en favor del consumidor. ¿Qué proveedores deben cumplir? R: la norma lo dice.

Artículo 17 B.- Los contratos de adhesión de servicios crediticios, de seguros y, en general, de cualquier producto financiero, elaborados por bancos e instituciones financieras o por sociedades de apoyo a su giro, establecimientos comerciales, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y toda persona natural o jurídica proveedora de dichos servicios o productos, deberán especificar como mínimo, con el objeto de promover su simplicidad y transparencia, lo siguiente: (y enumera un montón... el que se lo aprende de memoria se saca un 7 ipso iure presumido de derecho).

La pregunta es **¿Qué efecto se produce en el caso que el proveedor no cumpla con estos deberes de información?** R: se vicia la voluntad del consumidor por error. Si no recibo la información del contenido del contrato, se presta el consentimiento, pero ese consentimiento estaría viciado por error. La consecuencia de esa falta de información del consumidor y por lo tanto el hecho de que incurra en error, produce el efecto de la nulidad relativa.

Artículo 17 e) de la LPDC: “El consumidor afectado podrá solicitar la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones que infrinjan el artículo 17 b. Esta nulidad podrá declararse por el juez en el caso de que el contrato pueda subsistir con las restantes cláusulas o, en su defecto, el juez podrá ordenar la adecuación de las cláusulas correspondientes, sin perjuicio de la indemnización que pudiese determinar a favor del consumidor”.

Los efectos son 3:

- ✓ **Nulidad**
- ✓ **Mantención o conservación del contrato**
- ✓ **La indemnización de perjuicios**
 - **(*) Intervención judicial del contrato:** CARLOS PIZARRO WILSON dice que se hace presente la posibilidad de intervención judicial del contrato. Pero si se lee el 17 e) la norma no dice que puede intervenir en el contrato, sino que ordena a las partes intervenir en el contrato. Ahora, si el proveedor no adecúa las condiciones del contrato, al final esto quedaría en letra muerta. Si se ordena la adecuación de las cláusulas y no se cumple, entonces el juez a raíz de aquel incumplimiento podría intervenir en el contrato (y así lo dice un fallo que nos iba a enviar el profesor). ¿Pero tiene límites aquella modificación? R: El mismo ordenamiento jurídico, para solucionar el problema.

Estos efectos claramente se apartan del derecho civil o de la manualística. Hay un gran profesor de esta facultad que una vez nos dijo que **“los contratos se celebran para cumplirse”**. Esta es una clara manifestación de esa frase. Como se celebran para cumplirse, el derecho ha evolucionado, el derecho ha reconocido paradigmas que vienen incluso del derecho romano, donde el centro sería el interés a satisfacer (según Ihering). Esto lo dijo en la obra: “Espíritu del derecho romano” y su obra “La culpa

in contrahendo". Esto está vinculado a la gran influencia de la doctrina alemana en materia continental. Cuando el contrato apunta a efectos para que se cumpla el contrato, es correcto, ya que el motor de esto es el interés y la satisfacción de un interés.

3. Otro de los factores relacionados con la formación del consentimiento, **es el derecho a retracto.**

La regla general en materia de contratos es que no opera el retracto (desistimiento unilateral del consumidor del contrato), ya que vulnera el pacta sunt servanda (art. 1545). Hay ciertos casos en que se permite el retracto, no solo en materia de los derechos del consumidor. Ejemplo: la donación y el mandato son revocables, en la sociedad el socio puede retirarse.

Es la posibilidad del desistimiento unilateral del consumidor del contrato, la posibilidad que le entrega el legislador al consumidor para arrepentirse. **El fundamento del derecho a retracto** está dado fundamentalmente por la posibilidad de reflexión frente a ciertos supuestos, que está vinculado con la información y con la problemática de la razonabilidad imperfecta (recibo mucha información y esta información provoca desinformación).

Entonces, como el legislador entiende que la persona consiente libre en tanto esté informada, le concede en ciertos supuestos (enumerados en los Art. 3 bis y ter) la posibilidad de arrepentirse del contrato que ya está celebrado. Esto lo hace porque busca entregarle al consumidor la posibilidad de reflexión respecto de la celebración de ese contrato.

3 bis y 3 ter: características:

Artículo 3º bis. - El consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, en los siguientes casos: (...)

Artículo 3º ter.- En el caso de **prestaciones de servicios educacionales de nivel superior**, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, se faculta al alumno o a quién efectúe el pago en su representación para que, dentro del plazo de diez días contados desde aquél en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, deje sin efecto el contrato con la respectiva institución, sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados.

1. **Es absoluto:** no requiere expresión de causa por parte del consumidor. Esto porque dentro de ese periodo reflexionó y estimó que no era el producto que quería. Este es un derecho de retiro o de desistimiento unilateral del contrato absoluto.
2. **Expreso:** se le tiene que manifestar expresamente al proveedor que se retracta
3. **Sujeto a plazo:** 10 días según el artículo 3 bis.
4. **Casos en que procede:** 3 bis y 3 ter (aprenderse los casos que aparecen en el artículo)
5. **Opera de pleno derecho:** no requiere que se vaya a un tribunal para que este declare la terminación del contrato.

30 de mayo de 2018

iii. CLÁUSULAS ABUSIVAS Y LOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LA LPDC

3.1. Contexto histórico

¿Cómo se regulaban las relaciones entre proveedores y consumidores antes de la dictación de la LPDC? Hay que entender que el Código de Comercio fue dictado en el siglo 19, donde el derecho privado en su generalidad de regía por los principios de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad. **Las partes eran libres para obligarse, determinar con quién obligarse, y el contenido de la obligación que iban a contraer**, y se regían por el artículo 1545. El artículo 560 también refleja la libertad contractual, pues, en la interpretación de los contratos, hay que estar a lo que pactaron los contratantes. A la época de la dictación del Código de Comercio, los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad regían los contratos desde el momento de su formación.

"La libertad contractual se apoya en el supuesto de que las personas son libres e iguales, y, por lo tanto, protegiéndose esa libertad e igualdad, consustancial a todo ser humano, el resultado de toda negociación contractual debe ser bienvenido". Si las partes son iguales y son libres para obligarse, lógicamente la voluntad siempre va a ser suficiente para que un contrato sea equivalente entre las partes.

Se dicta el Código de Comercio, y comienzan a acontecer una serie de modificaciones en la economía mundial. Como ciencia social, el derecho tiene que adaptarse a los cambios de la sociedad: se pasa de una economía agraria a una economía industrial. El principal cambio es la rapidez con que se empieza a producir, tanto la contratación como la oferta de bienes y servicios. La producción aumenta de manera exponencial y, por ende, los productores de bienes y servicios también tienen que aumentar su oferta.

Todo esto genera que, de cierta manera, los principios que vimos anteriormente empiecen a ser dejados de lado ante la necesidad de una contratación rápida. Se empiezan a generar contratos tipo, que regulan de manera específica la prestación de ciertos servicios y la venta de ciertos bienes. Son contratos que tienen condiciones generales establecidas, normalmente, por una de las partes, y ante los cuales la otra parte simplemente tiene que adherir a sus condiciones. Lógicamente, esto empieza a impactar los principios generales de los que hablábamos. Hay una parte que determina las condiciones y la otra meramente lo acepta. Este es el contexto en que se empieza a necesitar una regulación específica para mantener un equilibrio entre las partes.

Como consecuencia de esta modificación en la forma de celebrar los contratos, surgen los llamados contratos de adhesión, que ahora son definidos por la LPDC. Al mismo tiempo, se hizo necesario reconocer la debilidad de las partes (el consumidor): se reconoce la figura del consumidor, y se necesita regular de manera especial su situación, para efectos de que los proveedores no les pasen por encima al establecer las condiciones de los contratos.

La doctrina comienza a decir que el principal fundamento de esta regulación especial es mantener el equilibrio entre las partes, o evitar el desequilibrio dado por el hecho de que solo una parte está determinando las condiciones de los contratos. Hay otros autores que, además de eso, dicen que la regulación tiene una finalidad determinada por el orden público económico: en ese sentido, para la economía es fundamental que los consumidores tengan confianza en el mercado y en los bienes y servicios que compran o contratan. De lo contrario, se generarían desincentivos al consumo, y la economía de vendría abajo.

3.2. Contratos de Adhesión

Están definidos en el artículo 1 N°6 de la LPDC.

Contrato de adhesión: aquel cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.

Con la generación de estos contratos de adhesión, fue necesario dictar reglas especiales para las cláusulas abusivas. Si un proveedor tiene la facultad de determinar, de manera unilateral, el contenido del contrato, es más probable que la persona encargada de dictar el acto o contrato va a velar más por sus intereses que por los de la otra parte. Se genera la necesidad de dictar reglas especiales sobre las cláusulas abusivas, ya que las solas reglas de la buena fe e interpretación de los contratos no fueron suficientes para llegar a una estructura de control y sanción para las cláusulas abusivas. Para mantener el equilibrio y el fin del orden público económico, se tuvo que limitar la libertad del proveedor. **De esto nacen las cláusulas abusivas.**

Es importante tener presente que la LPDC, si bien es de aplicación especial para las relaciones de consumo, regula situaciones que no están reguladas por el derecho común. Hay algunos autores que sostienen que, respecto a ciertos temas, como las cláusulas abusivas o los contratos de adhesión, esta ley es derecho común. No es supletorio ni especial exclusivamente para las relaciones de consumo, sino que para todas las áreas en que el derecho común no se ha pronunciado, la doctrina y parte de la jurisprudencia reconocen que estas normas son de aplicación general. Por eso es tan importante la regulación de esta materia.

3.3. Cláusulas Abusivas

Legislativamente, se han determinado distintas formas de definir las cláusulas abusivas o de reconocerlas. Primero, una definición abstracta, dando cuenta de que siempre que se cumplan ciertas situaciones, la cláusula va a ser determinada como abusiva y, por lo tanto, se atenderá a lo que diga el legislador. **Otra técnica** es establecer una lista de cláusulas abusivas y, en caso de que cualquiera de ellas sea incorporado en un contrato, se aplica la sanción determinada por el legislador. Una tercera opción es una técnica mixta, que establece un listado taxativo o no taxativo, más una definición general. Nuestra LPDC originalmente estableció un listado de cláusulas abusivas. Una modificación posterior incorporó una definición genérica, ya que había muchos casos en que había cláusulas que vulneraban los derechos de los consumidores pero que no estaban contenidos en el listado que establecía la ley. Ahora veremos una a una cuáles son las cláusulas que establece la Ley 19.496 de Protección a los Derechos de los Consumidores en su artículo 16.

Artículo 16.- No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

b) Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica;

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio;

f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato, y

g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales.

Si en estos contratos se designa árbitro, el consumidor podrá recusarlo sin necesidad de expresar causa y solicitar que se nombre otro por el juez letrado competente. Si se hubiese designado más de un árbitro, para actuar uno en subsidio de otro, podrá ejercer este derecho respecto de todos o parcialmente respecto de algunos. Todo ello de conformidad a las reglas del Código Orgánico de Tribunales.

En todo contrato de adhesión en que se designe un árbitro, será obligatorio incluir una cláusula que informe al consumidor de su derecho a recusarlo, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Lo que se entiende sin perjuicio del derecho que tiene el consumidor de recurrir siempre ante el tribunal competente.

Se parte reconociendo que la ley, al regular las cláusulas abusivas, lo primero que determina es su efecto, y dice que no producirán efecto alguno. Hay una discusión en la doctrina civil: **¿a qué se apareja no producir efecto alguno? Puede ser inexistencia o nulidad, pero en la práctica no hay mucha diferencia.** En la modificación que se hizo posteriormente al artículo, se incorporó la letra (g).

- Cláusulas que "otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen".

La contra excepción es cuando esta prerrogativa se otorga al consumidor. Esta es una regla lógica. Si esto fue necesario regularlo expresamente, es porque lo que se prohíbe actualmente se hacía. Independiente de que hubo un cambio en la normativa y las reglas generales que desplazaban los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad, un contrato válidamente celebrado igual es ley para las partes, y no puede ser dejado sin efecto unilateralmente. Es decir, se aplica el artículo 1545 del Código Civil. Se limita la posibilidad de que se pacte una cláusula en que una de las partes pueda dejar sin efecto el contrato, sobre todo el proveedor.

- Cláusulas que "establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica".

No pueden cambiar las condiciones del contrato una vez que el contrato ya ha sido celebrado, a menos que le incremento en el precio signifique una prestación mejor de los servicios o un bien adicional, siempre que el consumidor tenga la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo.

- Cláusulas que "pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables".

Es decir, que, en caso de cualquier incumplimiento del proveedor, se determine que esto será de cargo del consumidor.

- Cláusulas que "inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor".

La regla general es que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta. Lo que busca esta regulación es que los proveedores no digan que la carga de probar la existencia de una obligación o su extinción va a ser solamente del consumidor, aunque no lo aleguen.

- Cláusulas que "contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio".

El proveedor no puede limitar su responsabilidad en relación al bien o servicio que prestan. Por ejemplo, el típico problema que se originaba en los malls o estacionamientos en que se robaban autos o se robaban algo del auto, y decían que el mall no se hacía responsable de los robos que ocurrieran dentro de su estacionamiento. Obviamente, esta cláusula no es válida por esta limitación. El mall, al estar prestando un servicio de estacionamiento, es responsable de lo que pase en él.

- Cláusulas que "incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato".

De lo contrario, el proveedor los puede llenar como quiera.

-
- Cláusulas que "en contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efectos a parámetros objetivos, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. Se presumirá que dichas cláusulas se encuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades legales".

A raíz de una modificación el año 2011, se incorporó una definición abstracta y completa de qué se va a entender por una cláusula abusiva. Para hablar de la buena fe, hay que distinguir entre la buena fe objetiva y subjetiva. **La buena fe subjetiva tiene que ver con el convencimiento de estar actuando conforme a derecho, y la objetiva se entiende incorporada al contrato y se relaciona con el deber de lealtad a cumplir la obligación.**

Es decir, las cláusulas abusivas son aquellas que están en contra de las exigencias de la buena fe objetiva, que causan un perjuicio al consumidor (que vulnera alguno de sus derechos), y que suponga un desequilibrio importante para las partes. La ley 20.555 (que modificó la LPDC) llenó una especie de vacío que existía desde la dictación de la LPDC, definiendo lo que se entiende por cláusula abusiva. Hasta antes de la dictación de esta ley, se discutía si el listado era taxativo, etc. Este numeral rellena la laguna que se había generado. Si bien no se refiere exclusivamente a las cláusulas abusivas, sí tiene que ver con los deberes que tienen los proveedores al momento de celebrar estos contratos de adhesión.

La doctrina distingue entre requisitos de forma y de fondo. Los requisitos de fondo tienen que ver con las cláusulas abusivas, y los de forma son requisitos que establece la LPDC respecto a la redacción del contrato. La letra, por ejemplo, no puede ser inferior a 2,5 mm, tiene que ser en idioma castellano (a menos que el consumidor acepte otro idioma), etc.

3.4. Efectos de las cláusulas abusivas

Cuando empezamos a ver el artículo 16, sabemos que no producen efecto alguno. Ahora, a nivel jurisprudencial, se ha comenzado a observar que, muchas veces, los tribunales optan por alterar a cláusula, para efectos de que deje de ser abusiva, más que ésta deje de tener efecto. Es decir, aunque la ley imponga una sanción específica, nuestros tribunales (aunque no de manera uniforme) han optado por alterar las condiciones del contrato, modificando la cláusula en aquello que la hace abusiva.

3.5. Tipos de Responsabilidad en la LPDC

Esto se relaciona con lo visto anteriormente. Hay que entender cuál es la finalidad de esta ley: si bien vela por interés de los consumidores considerados de manera individual, también lo hace respecto a los consumidores considerados de manera colectiva. Parte de la regulación tiene una finalidad social para el orden público económico respecto a la seguridad de los consumidores, para que éstos puedan comprar con ciertas garantías.

La LPDC establece dos tipos de sanciones, en términos muy generales. Establece una sanción para el proveedor que infringe la ley, y que la doctrina mayoritaria lo asocia a un derecho administrativo sancionador, y una doctrina minoritaria que lo asocia al derecho penal.

La ley regula o establece responsabilidad para los proveedores desde dos puntos de vista: **(1) por infracción a la ley,** y **(2) por la responsabilidad civil que se origina en el incumplimiento del contrato o del acto de consumo que se celebra con el consumidor.**

La responsabilidad se puede definir como la necesidad de cumplir una obligación. El origen de esa obligación va a determinar si la responsabilidad es contractual o extracontractual. **La LPDC converge ambos tipos de responsabilidad para el proveedor.**

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.

Dentro del marco de la LPDC, la responsabilidad del proveedor puede ser observada desde dos perspectivas: la perspectiva civil, en virtud de la relación que tiene con el consumidor, o de una perspectiva infraccional, que dice relación con el incumplimiento que la ley impone a los proveedores.

En materia de responsabilidad civil, el incumplimiento de un contrato va a otorgar a la parte cumplidora ciertos derechos: solicitar indemnización de perjuicios, cumplimiento forzado, o la resolución del contrato, además de ciertos derechos auxiliares. Lo determinante para que se origine la responsabilidad en materia civil es el incumplimiento del contrato. En el marco de la LPDC, lo importante para que se origine la responsabilidad del proveedor es la infracción a la ley. Como la ley regula ambos tipos de responsabilidades, no queda claro cuándo se origina una o la otra. La doctrina obviamente tiene una discusión al respecto, acerca de si necesariamente, para que surja la responsabilidad civil, se requiere infracción de la ley o no.

La regulación de la responsabilidad civil tiene que ver necesariamente con la relación de consumo que se establece dentro del ámbito de protección de la LPDC. Por ende, para que esta ley opere, necesariamente tiene que haber una relación de consumo.

La doctrina civil distingue la responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Cabe la responsabilidad extracontractual para aplicar esta ley, si es que necesariamente se necesita una relación de consumo? A primera vista no, ya que esta relación ya presupone una relación contractual. Sin embargo, en muchos casos, el legislador impone obligaciones al proveedor. Por ejemplo, la jurisprudencia ha reconocido que, si alguien está en un mall, antes de que exista una relación de consumo y la persona se cae porque el piso está mojado, esto se regula por la LPDC, no se requiere una relación de consumo y, por ende, se genera responsabilidad extracontractual.

Por otro lado, tenemos la responsabilidad infraccional, aquella que se origina con la contravención de una norma prohibitiva o imperativa de la ley, aun cuando no se haya materializado el acto de consumo. ¿Cuál es el efecto asociado al origen de la responsabilidad civil en materia de protección a los derechos del consumidor? R: la indemnización de perjuicios, y la ley lo establece en diversas disposiciones.

Por ejemplo, el artículo 3 (e) de la LPDC, que reconoce el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del proveedor, y el derecho a reaccionar con cualquiera de los medios que la ley establece.

En caso de que se origine la responsabilidad infraccional del proveedor, el artículo 50 inciso segundo establece: "El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ley dará lugar a las acciones destinadas a sancionar al proveedor que incurra en infracción, anular las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, obtener la prestación de la obligación incumplida, hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de los consumidores, a obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda".

La LPDC regula distintos tipos de responsabilidad: civil e infraccional. La discusión doctrinaria responde a qué relación existe en estos dos tipos de responsabilidad. Además, la ley no regula estas dos responsabilidades de manera orgánica, sino que hay artículos diseminados. Frente a esto, la doctrina ha establecido dos teorías:

- ✓ **La tesis de la diferenciación de las contravenciones:** en todo incumplimiento determinado dentro de las obligaciones que establece la ley va a surgir, o bien responsabilidad civil, responsabilidad infraccional, o ciertas situaciones mixtas van a originar los dos tipos. Principalmente, porque, si bien están reguladas conjuntamente en la ley, el tratamiento que se le da a cada una es distinta.

Por ejemplo, cuál es el procedimiento aplicable, cuáles son los tribunales competentes, cuáles son los plazos de prescripción que se aplican, etc. La LPDC establece un plazo de prescripción de 6 meses para alegar la responsabilidad infraccional de los proveedores, pero si una situación genera un perjuicio civil, ¿será razonable un plazo de prescripción de 6 meses, o se requiere el plazo común? Para esta doctrina, es importante hacer la distinción y decir que, si tal hecho genera uno u otro tipo de responsabilidad, cada uno es distinto y cada uno se regirá por sus propias reglas. Para esto, dan una serie de ejemplos:

- ❖ **Cláusulas abusivas:** frente a ellas, la ley no establece una multa particular, sino que establece una sanción específica: la nulidad. Ahora bien, esta cláusula abusiva también puede generar un perjuicio civil. Por lo tanto, si bien no se aplica una multa, el consumidor sí podrá alegar indemnización de perjuicios.
- ❖ **Responsabilidad infraccional:** hay ciertos casos en que se va a producir el ilícito infraccional y que no necesariamente generan un perjuicio. Por ende, no habrá responsabilidad civil. Por ejemplo, que el contrato de adhesión tenga un tamaño de letra más pequeño que el mandado por la ley.
- ✓ **Tesis unitaria:** cualquier norma que vulnere la LPDC puede hacer surgir la responsabilidad civil y la infraccional. Esta tesis se basa, primero, en el artículo 50 (que establece que cualquier infracción hará responsable al proveedor), el artículo 24 (que establece las multas que se aplican al proveedor, y lo hace de manera amplia),

etc. La responsabilidad civil se va a generar cuando, de acuerdo al derecho común, se den los requisitos y presupuestos necesarios para que ésta se origine.

4. SERNAC

Este servicio también está regulado en la LPDC, definido en los artículos 57 y siguientes, que también establecen sus facultades. El SERNAC vela por los intereses de los consumidores en sentido amplio, no por el interés de un consumidor en particular. Una de sus funciones es educar al mercado, tanto a los consumidores como a los proveedores.

Artículo 57.- El Servicio Nacional del Consumidor será un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente en todas las regiones del país, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 58.- El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor.

31 de mayo de 2018

Respecto del proyecto de ley que busca otorgar nuevas facultades al Sernac:

- i. **Facultad de fiscalizar**
- ii. **Facultad de sancionar**
- iii. **Facultades interpretativas y normativas**
- iv. **Facultad propositiva**
- v. **Aumento de plazos de prescripción:** responsabilidad infraccional -> de 6 meses a 2 años. Plazo de prescripción de las acciones civiles (indemnización de perjuicios), se dispone de forma expresa que se aplicarán las reglas generales del Código Civil (5 años si hay contrato, y 4 años si no lo hay)
- vi. **Incremento de multas y su determinación:** 50 UTM a 300 UTM. Con aplicación de nuevas atenuantes, agravantes y beneficios para las PyMes.

A través de modificaciones como estas, el legislador busca, que **se diferencie la responsabilidad civil de la infraccional, también, dotar este órgano de potestades más fuertes.**

Respecto de las modificaciones a los procedimientos de la LPDC, el proyecto de ley plantea:

- o **Procedimiento ante los juzgados de Policía Local:** se mantiene a la competencia de los juzgados de policía local para conocer de las causas en que los consumidores, a título individual, ejercen una acción de indemnización de perjuicios y/o infraccional en contra del proveedor. Sin embargo, se modifica el criterio en virtud del cual serán competentes dichos tribunales. Será competente, como único criterio, el tribunal de la comuna del consumidor o del proveedor, a elección del consumidor.

- **Nuevo procedimiento administrativo sancionatorio ante el SERNAC:** se planea la creación de una serie de cuerpos dentro del Sernac que lleven adelante los procedimientos. Así, el procedimiento se va a iniciar de la siguiente manera: a solicitud del Sernac, dicho ente (Sernac) podrá solicitarle antecedentes a un proveedor, y este tendrá un plazo de 10 días para otorgarlos. Junto con estos antecedentes el proveedor va a tener que proponer soluciones al conflicto y en caso de que al Sernac, al proveedor o al consumidor no le parezcan adecuadas estas soluciones, se va a dar por finalizada la etapa de mediación (la etapa de mediación es uno de los nuevos elementos más relevantes que se busca incorporar con el proyecto) y se dará inicio a un proceso sancionatorio que va a ser llevado ante la dirección regional, donde el instructor regional del Sernac tendrá un plazo para resolver el caso y presentarle la solución al director regional, y este último determinará si sanciona o no sanciona al proveedor. Si se le sanciona, el proveedor puede recurrir al juzgado de policía local y en caso de que la sanción que se le aplique sea mayor a la que establece la ley, el proveedor podrá recurrir a la Corte de Apelaciones. De esta manera, se está dotando al Sernac de facultades jurisdiccionales.
- **Además, el proyecto de ley modifica en cierto sentido las acciones colectivas:** hoy el Sernac puede representar los intereses de los consumidores, pero esos procedimientos se desarrollan en los tribunales ordinarios de justicia, no ante los juzgados de policía local. En este tipo de procedimientos, se han regulado una serie de aspectos dentro del mismo procedimiento:
 - ✓ **En materia de medidas precautorias,** en casos calificados y sólo una vez admitida a tramitación la demanda, el juez podrá ordenar que el proveedor cese provisionalmente el cobro de los cargos cuya procedencia esté siendo cuestionada en juicio.
 - ✓ **En materia indemnizatoria,** una de las principales modificaciones que incorpora el proyecto, es la posibilidad de que los consumidores soliciten indemnización de perjuicios por daño moral en procedimientos colectivos, lo cual está actualmente prohibido por la LPC. La indemnización del daño moral se hará efectiva mediante la determinación judicial de un monto mínimo común que corresponde a la afectación mínima sufrida por los consumidores en común por la infracción respectiva.
 - ✓ **Se le reconoce al tribunal la potestad de aplicar multas, en razón de la cantidad de consumidores que están siendo afectados.** Que pueden llegar hasta un máximo del 30% de lo que el proveedor recibe por el bien o servicio que está prestando, y con un máximo de 45.000 UTM.

Hoy en día Sernac tiene una función de velar por los intereses de los consumidores, de informales, pero carece de ciertas herramientas para hacerlo. Es por esto que el legislador generó este proyecto. Respecto a esto, el Tribunal constitucional este año dictó sentencia, y declaró inconstitucional el proyecto por tres cosas principalmente:

- **Las atribuciones jurisdiccionales que se buscaba darle al Sernac,** esto en virtud de que los únicos órganos jurisdiccionales son los tribunales.
- **La potestad normativa,** el Sernac tendría potestad para dictar regular de manera general ciertas normativas.
- **La potestad de solicitar antecedentes,** puesto que el otorgamiento de esta información puede afectar derechos de los particulares (intimidad y vida privada).

De esta manera, se mantienen las demás modificaciones que no se consideraron inconstitucionales, pero estos puntos no pueden llevarse a efecto.

VI.

CONTRATO DE TRANSPORTE

El contrato de transporte en términos amplios el legislador no lo define, sino que se definen los contratos de este tipo de modo particular (aéreo, terrestre, marítimo y multimodal), es por esto que la doctrina reconoce la definición de contrato de transporte como el transporte terrestre porque conserva los elementos esenciales de este tipo de contratos.

De esta manera, los define como “La conducción de personas o cosas de un lugar a otros”.

Artículo 166 del Código de Comercio:

El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas.

Llámanse porteador el que contrae la obligación de conducir.

El que hace la conducción por agua toma el nombre de patrón o barquero.

Denomínase cargador, remitente o consignante el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción. Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario.

La cantidad que el cargador o, en su caso, el consignatario, están obligados a pagar por la conducción, se llama porte.

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transportes, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo.

OJO: Esta es la definición de contrato de transporte terrestre, no la de transporte marítimo (marítimo es solo en mar).

Naturaleza jurídica del contrato de transporte terrestre: Históricamente la doctrina ha dicho que se trata de un contrato de arrendamiento (según los artículos 2013 y siguientes del Código Civil) y reconocía también que participaba de las características del depósito.

Hoy en día, el contrato de transporte es un contrato **autónomo, nominado y generalmente mercantil**.

1. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

1.1. Subjetivos:

Quienes son las partes del contrato de transporte, se encuentran definidas en el artículo 166 del Código de Comercio:

- ❖ **Porteador:** transportista, es la persona que asume la obligación de transportar a las personas o cosas de un lugar a otro.

- ❖ Patrón o barquero: el que hace la conducción por agua.
- ❖ Cargador o remitente: quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción
- ❖ Consignatario: es la persona a quien deben entregarse las mercaderías. Puede pasar que el cargador y el consignatario sean la misma persona.

1.2. Objetivos:

- ❖ Porte: es el precio que debe pagar el cargador o el consignatario, en razón del contrato de transporte terrestre.
- ❖ Obligación: del transportista de llevar las mercaderías de un lugar a otro.

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

- **Mercantil**: regulado en el Código de Comercio.
- **Bilateral**
- **Consensual**
- **Nominado**
- **Principal**: si bien como acto jurídico es principal, no necesita de otro acto jurídico para subsistir. En la práctica, siempre está asociado comercialmente a otro contrato (la mayoría de las veces). (Ejemplo: si compro un producto por el cyber monday, el contrato de transporte de ese producto está asociado a la compraventa del producto). Esto es importante porque eventualmente, incluso durante la ejecución del contrato, el remitente puede dejar sin efectos el contrato. Caso en que va a tener que pagar parte del porte.
- **Oneroso**

3. ¿CÓMO SE CLASIFICA EL CONTRATO DE TRANSPORTE?

3.1. Según la vía utilizada para el transporte:

- Terrestre: conducción por tierra, canales, lagos o ríos navegables.
- Aéreo: conducción por aire.
- Marítimo: conducción por mar.
- Multimodal: aquel en que se mezclan distintas vías de conducción.

3.2. Según el objeto del contenido de la conducción:

- Cosas
- Mercaderías
- Personas

3.3. Según el sujeto que realiza la conducción:

- Empresas (particulares o públicas): por ejemplo, LAN o Tur bus.
- Sujetos que no están organizados como empresa: por ejemplo, los taxis.

4. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Se encuentra en el artículo 166 del Código de Comercio:

El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas.

Llábase porteador el que contrae la obligación de conducir.

El que hace la conducción por agua toma el nombre de patrón o barquero.

Denomínase cargador, remitente o consignante el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción. Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario.

La cantidad que el cargador o, en su caso, el consignatario, están obligados a pagar por la conducción, se llama porte.

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transportes, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo.

Adicionalmente existe una definición doctrinaria que señala que el contrato de transporte terrestre es: *aquel contrato en que una de las partes se obliga, a cambio de un precio, a realizar las operaciones necesarias para trasladar de un lugar a otro o una cosa, en las condiciones que hubieran pactado las partes.*

a) Respecto a la obligación principal (trasladar las cosas de un lugar a otro):

- Es una obligación de hacer
- De resultado
- Personalísima

b) El precio del contrato de transporte se llama porte, y es posible distinguir dos tipos:

- Si la obligación la asume el remitente, el porte va a ser un **porte pagado**.
- Si la obligación la asume el consignatario, el porte será un **porte devenido** y se pagará una vez realizada la entrega. En este caso, el remitente siempre va a quedar sujeto al cumplimiento de la obligación, así, si el consignatario no paga, vuelve la obligación al remitente.

c) Carta de porte

Como el contrato es consensual, se perfecciona por la sola concurrencia de la voluntad de las partes. Pero por un tema de seguridad se crea la carta de porte que tiene por finalidad estipular las condiciones del contrato. **Esto no hace que el contrato sea solemne, el contrato sigue siendo consensual pero la carta de porte tiene por objeto acreditar existencia, estipulaciones y observaciones respecto de las condiciones y la calidad en que se le entregaron la mercadería al transportista.** (Se deja reporte de las condiciones en que se recibe la mercadería).

La carta de porte también es un título de crédito que permite transferir las mercaderías que se están transportando. Así, la carta de porte va a poder ser, dependiendo de la forma de constituir el dominio:

- Nominativa → a través de la cesión de crédito
- A la orden → por medio del endoso

- Al portador → por la simple tradición o la entrega

La forma en que se constituya la carta de porte va a determinar la ley de circulación de la misma.

Artículo 173 del Código de Comercio define carta de pago: *Llámase carta de porte el documento que las partes otorgan para acreditar la existencia y condiciones del contrato, y la entrega de las mercaderías al porteador.*

Además, el artículo 175 establece que:

La carta de porte debe expresar:

- 1°. El nombre, apellido y domicilio del cargador, porteador y consignatario;
- 2°. La calidad genérica de las mercaderías, su peso y las marcas y número de los bultos que las contengan;
- 3°. El lugar de la entrega;
- 4°. El precio de la conducción y la designación del obligado al pago;
- 5°. El plazo en que debe hacerse entrega de la carga;
- 6°. El lugar, día, mes y año del otorgamiento;
- 7°. El nombre, apellidos y firma de las personas que concurren a su otorgamiento, presumiéndose que éstas representan al cargador y al porteador, y
- 8°. Cualesquiera otros pactos o condiciones que acordaren los contratantes.

La carta de porte, en primer lugar, tiene por objeto acreditar la existencia del contrato y también las asegurar el cumplimiento de las cláusulas que las partes han pactado. De la misma forma, como medio de prueba el artículo 178 establece que: *No se admitirán contra el tenor de la carta de porte otras excepciones que las de falsedad, omisión y error involuntario.*

Además, la carta de porte significa un título de crédito, dependiendo de qué manera se otorgó la carta (nominativa, a la orden o al portador). Adicionalmente establece una subrogación legal, pues la persona que adquiere la carta de porte pasa a tomar el lugar del consignatario.

4.1. Fases del contrato de transporte terrestre:

- **Entrega de la mercadería al porteador:** el remitente le entrega las cosas al porteador.
- **Transporte:** Debe realizarse por la ruta que se ha pactado, tan pronto sea posible.
- **Llegada de la mercadería al destino:** debe hacerse en el lugar indicado por las partes y a la persona indicada en la carta de porte.

4.2. Efectos del contrato de transporte

4.2.1. Obligaciones del cargador

- a) **Entregar la mercadería** (artículo 180 del Código de Comercio: *El cargador está obligado a entregar las mercaderías al porteador bien acondicionadas y en el tiempo y lugar convenidos, y a suministrarle los documentos necesarios para el libre tránsito o pasaje de la carga. Añade el artículo 181: No habiendo carta de porte, o no enunciándose en ella el estado de las mercaderías, se presume que han sido entregadas al porteador sanas y en buena condición.*) Los efectos del incumplimiento de esta obligación son que el transportista va a poder pedir la resolución del contrato más la mitad del porte que se hubiere pactado, o si es que el porteador quiere perseverar en el contrato deberá el remitente pagar los

costos adicionales que se le hubiesen originado al porteador por el atraso o bien la entrega en un lugar distinto del pactado.

Antiguamente (2001 aprox.) se exigía la guía de despacho, pero esa fue reemplazada por la carta de pago.

- b) **Pagar el precio**, el cargador debe pagar el porte convenido. A quien le corresponde normalmente el pago del porte es al consignatario, pero en caso de que este no pague, el transportista va a poder ir a cobrarle al cargador.

4.2.2. Derechos del cargador

- a) Dejar sin efecto por su sola voluntad el contrato. Incluso una vez iniciado el transporte de la mercadería; como consecuencia de esto, va a tener que pagar la mitad del porte, lo que en doctrina se denomina *falso porte*.
- b) Cambiar el destino o consignación de la mercadería. Para hacerlo, debe modificar la carta de porte. Si es que este cambio de ruta o consignación hace más gravosa la obligación para el transportista, este último podrá no consentir en ella, y cumplirá la obligación original simplemente dejando la mercadería en el lugar pactado originalmente.
- c) La ley le reconoce un privilegio de segunda clase para ser pagado en las indemnizaciones.

13 de junio de 2018

Artículos del profesor referidos a transporte:

Ya vimos transporte terrestre. Hay que tener clara la definición del artículo 166 del Código de Comercio. Hay que tener claras las partes, también en el artículo 166. Hay que saber que es la carta de porte (título de valor representativo de mercadería). Es importante los efectos del contrato, los derechos y obligaciones del cargador, consignatario y del porteador. Finalmente. En materia de transporte, es importante el régimen de prescripción. Se aparta de la regla general que es 4 años (art. 822 del Código de Comercio). Artículo 214 N°4.

Luego, en el contrato de transporte marítimo. Debemos saber. Artículo 974 y siguientes del Código de Comercio. La definición del artículo 974. Las partes son porteador, cargador, consignatario (art. 975). Carta de porte (título de valor representativo de mercaderías)

Transporte multimodal. Este transporte tiene una modalidad muy genial, ya que es transfronterizo. Este transporte está definido en el **artículo 1041 N° 1 y 3**. Hay que estudiar las partes: Operador, expedidor y consignatario también 1041. El documento que en este caso es la carta de porte multimodal.